

Business und Recht 2

Zusammenfassung

Autorinnen und Autoren

Katharina Tschirky

Datum

19 June 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Gesetzessammlung	4		
1.1. Obligationenrecht	4		
1.2. ZGB	4		
1.3. Arbeitsrecht	4		
1.3.1. Wichtige Artikel aus dem Arbeitsrecht	5		
1.4. Werkvertrag	6		
1.5. Auftrag	6		
1.6. Haftpflicht- und Produkterecht	6		
1.7. IT-Verträge	7		
2. Obligationenrecht - Erklärungen	8		
2.1. Entstehung einer Obligation	8		
2.2. Rechtssubjekte (Personen)	8		
2.3. Culpä in contrahendo	8		
2.4. Verträge	8		
2.4.1. Grundsatz der Vertragsfreiheit (Art. 19 OR)	9		
2.4.2. Voraussetzungen für Verträge	9		
2.4.3. Gesetzliche Bestimmungen	9		
2.4.4. Vertragstypen	9		
2.4.5. Formvorschriften	10		
2.4.6. Vertragsform	10		
2.4.7. Stellvertretung	10		
2.4.8. Vertragsschluss (Art. 1 OR)	11		
2.4.8.1. Ausdrückliche Willensäußerung .	11		
2.4.8.2. Konkludente Willensäußerungen .	11		
2.4.9. Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB's)	12		
2.4.10. Erfüllung der Obligation	12		
2.4.10.1. Ort der Erfüllung	12		
2.4.10.2. Erfüllungstörungen	13		
2.4.10.3. Schuldnerverzug anhand des Kaufvertrages	15		
2.4.10.4. Ablauf	15		
2.4.10.5. Voraussetzungen	15		
2.4.10.6. Verzugsfolgen	15		
2.4.10.7. Zusammenfassung Verzug	15		
2.4.10.8. Erfüllungszeit	15		
2.4.11. Übersicht Inhalts-/Willensmangel .	16		
2.4.12. Wesentlicher Irrtum	16		
2.4.13. Verjährung	17		
2.4.13.1. Beispiele	17		
2.4.14. Beispiele	17		
2.5. Erlöschen der Obligation	18		
3. IT-Verträge	19		
3.1. Eigenschaften	19		
3.2. Erscheinungsformen	19		
3.3. Leistungsstörungen	20		
3.4. Mängelrechte	20		
3.5. Risiken/Probleme	21		
3.6. Regelungspunkte	21		
3.6.1. Leistung und Preis	21		
3.6.2. Nutzung und Lizenzen	21		
3.6.3. Datenschutz und Geheimhaltung .	21		
3.6.4. Mängel, Gewährleistung und Haftung	21		
3.6.5. Vertragsende	21		
3.7. Mögliche Vertragsklauseln	21		
3.7.1. Gewährleistung und Abnahme	21		
3.7.2. Haftung	21		
3.8. Outsourcingvertrag	22		
3.8.1. Regelungspunkte	23		
4. ZGB - Erklärungen	24		
4.1. Anwendung des Rechts (Art.1 ZGB) .	24		
4.2. Treu und Glauben (Art. 2 ZGB)	24		
4.3. Guter Glaube (Art. 3 ZGB)	24		
4.4. Gerichtliches Ermessen (Art. 4 ZGB) ..	25		
4.5. Beweisregel (Art. 8 ZGB)	25		
5. Arbeitsrecht	26		
5.1. Nominatverträge	26		
5.1.1. Arbeitsvertrag	26		
5.1.2. Werkvertrag	26		
5.1.3. Auftrag	26		
5.1.4. Abgrenzung	26		
5.2. Rechtsgrundlagen zum Arbeitsrecht .	27		
5.3. Entstehung eines Arbeitsverhältnisses	27		
5.3.1. Einzelarbeitsvertrag (EAV)	27		
5.3.2. Besondere Einzelarbeitsverträge ...	27		
5.3.3. Gesamtarbeitsvertrag (GAV)	27		
5.3.4. Normalarbeitsvertrag (NAV)	27		
5.4. Aufbau Arbeitsvertrag	28		
5.5. Pflichten des Arbeitnehmers	28		
5.5.1. Persönliche Arbeitspflicht (Art. 321 OR)	28		
5.5.2. Befolgung von Anordnungen und Weisungen (Art. 321d OR)	28		
5.5.3. Sorgfalts- und Treuepflicht (Art. 321a OR)	28		
5.5.4. Geheimhaltung von Fabrikations- und Geschäftsgeheimnissen (Art. 321a Abs. 4 OR)	28		
5.5.5. Haftung des Arbeitnehmers aus Vertragsverletzung (Art. 321e OR) .	29		
5.5.6. Überstundenarbeit (Art. 321c OR) .	29		
5.5.7. Abgrenzung Überstunden / Überzeit	29		
5.6. Konkurrenzverbot (Art. 340 ff. OR) ...	29		
5.7. Pflichten des Arbeitgebers	30		
5.7.1. Lohn (Art. 322 ff. OR)	30		
5.7.2. Lohn bei Verhinderung der Arbeitsleistung (Art. 324 ff. OR)	30		
5.7.3. Lohnfortzahlung bei Verhinderung des Arbeitnehmers (Art. 324a OR)	30		
5.7.4. Schutz der Persönlichkeit des Arbeitnehmers (Art. 328 OR)	31		
5.7.5. Erstellen eines Arbeitszeugnisses(Art. 330a OR)	31		
5.7.5.1. Form des Arbeitszeugnisses	31		

5.8. Beendigung des Arbeitsverhältnisses .	31	9.1.6. Fall 6: Halskette gefällt nicht	46
5.9. Die Kündigung (Art. 335c OR)	32	9.1.7. Fall 7: Vertauschte Preisschilder	47
5.9.1. Kündigung während der Probezeit (Art. 335b OR)	32	9.2. ZGB	47
5.9.2. Kündigungsschutz	33	9.3. Arbeitsrecht	48
5.9.3. Missbräuchliche Kündigung	33	9.4. Diverse Fälle	50
5.9.4. Zeitlicher Kündigungsschutz (Art. 336c OR)	34	Glossar	52
5.9.4.1. Sperrfristen	34		
5.10. Ausserordentliche Kündigung / Fristlose Kündigung (Art. 337 OR) . . .	34		
5.11. Rechte an Erfindung und Designs (Art. 332 OR)	35		
6. Werkvertrag (Art. 363 OR)	37		
6.1. Höhe der Vergütung	37		
6.1.1. Keine oder nur ungefähre Preisvereinbarung (Art. 374 OR)	37		
6.1.2. Vergütung nach der SIA - Norm 118	37		
6.2. Mangelhaftung (Art. 367ff. OR)	37		
6.2.1. Seit Januar 2026	38		
6.2.2. Folgen bei Mängel	38		
6.3. Verzug (Art. 366 sowie 102 OR)	38		
6.4. Art. 365 OR - Betreffend den Stoff . . .	39		
7. Auftrag	40		
7.1. Auftragsarten	40		
7.2. Annahme des Auftrags (Art. 394 OR) .	40		
7.3. Sorgfaltspflicht und Treuepflicht (Art. 398 OR)	40		
7.4. Rechenschaftspflicht und Herausgabepflicht (Art. 400 OR)	40		
7.5. Beendigung des Auftrags (Art. 404 OR)	40		
8. Haftpflichtrecht	41		
8.1. Ausservertragliche Haftung	41		
8.1.1. Verschuldenshaftung (Art. 41 OR) . .	41		
8.1.2. Kausalhaftung	41		
8.1.2.1. Milde Kausalhaftung	41		
8.1.2.2. Scharfe Kausalhaftung	41		
8.1.3. Gefährdungshaftung	41		
8.1.4. Vertragliche Haftung (Art. 197 OR) .	41		
8.2. Produkthaftpflicht (Grundsatz) (Art. 1, 2, 4 PrHG)	42		
8.2.1. Fehlerbegriff	43		
8.2.2. Voraussetzungen	43		
8.2.3. Ausnahmen von der Haftung	43		
8.2.4. Anwendungsfälle	43		
9. Fallbeispiele	45		
9.1. Obligationenrecht	45		
9.1.1. Fall 1: Zerbrochene Vase im Möbelhaus	45		
9.1.2. Fall 2: Bestelltes Mobiltelefon	45		
9.1.3. Fall 3: Falscher Gesamtpreis in der Offerte	45		
9.1.4. Fall 4: Verkauf der Kakteensammlung	46		
9.1.5. Fall 5: Occasions-Sportwagen mit manipuliertem Kilometerstand	46		

1. Gesetzessammlung

1.1. Obligationenrecht

Thema	Artikel	Bedeutung
Entstehung einer Obligation	Art. 1-67 OR	Vertrag, unerlaubte Handlung und ungerechtfertigte Bereicherung
Weitere Rechtsgründe	Art. 419 ff. OR; Art. 2 ZGB	Geschäftsführung ohne Auftrag und culpa in contrahendo
Vertragsschluss	Art. 1, 6, 7, 9 OR	Willensäusserung, stillschweigende Annahme, verbindlicher Antrag und Widerruf
Form und Stellvertretung	Art. 11, 13-15, 32, 38-39 OR	Formfreiheit, Schriftlichkeit, Handeln durch Vertreter und fehlende Ermächtigung
Inhalts- und Willensmängel	Art. 20-29 OR; Art. 8 UWG	Nichtigkeit, Übervorteilung, Irrtum, Täuschung, Drohung und missbräuchliche AGB
Erfüllung und Erfüllungsstörungen	Art. 68, 74-75, 91, 97-109 OR	Erfüllung durch den Schuldner, Ort/Zeit der Erfüllung, Gläubigerverzug, Nichterfüllung und Schuldnerverzug
Verjährung	Art. 127-128, 130 OR; Art. 210, 371 OR	allgemeine und besondere Verjährungsfristen sowie Beginn der Verjährung
Erlöschen der Obligation	Art. 115-126 OR	Aufhebung, Neuierung, Vereinigung, nachträgliche Unmöglichkeit und Verrechnung
ZGB-Bezüge	Art. 28, 328, 641, 934 ZGB	Persönlichkeitsschutz, Verwandtenunterstützung, Eigentums- und Besitzesschutz

1.2. ZGB

- **Art. 1 ZGB:** Anwendung des Rechts; Gesetz, Gewohnheitsrecht und richterliche Regelbildung.
- **Art. 2 ZGB:** Treu und Glauben; Verbot des Rechtsmissbrauchs.
- **Art. 3 ZGB:** Guter Glaube wird vermutet, solange Bösgläubigkeit nicht bewiesen ist.
- **Art. 4 ZGB:** Gerichtliches Ermessen; Entscheidung nach Recht und Billigkeit.
- **Art. 8 ZGB:** Beweisregel; wer Rechte aus einer Tatsache ableitet, muss sie beweisen.

1.3. Arbeitsrecht

- **ArGV 1:** Enthält Definitionen und Präzisierungen zum Arbeitsgesetz, z.B. zu Arbeitszeit, Pausen, Ruhezeiten, Nacht- und Sonntagsarbeit, Sonderschutz von Frauen sowie Organisation der Behörden.
- **ArGV 2:** Enthält Sonderbestimmungen für bestimmte Betriebe oder Arbeitnehmergruppen. Sie erlaubt bei besonderen Verhältnissen Abweichungen von gesetzlichen Arbeits- und Ruhezeitvorschriften.
- **ArGV 3:** Regelt den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, z.B. Anforderungen an Räume, Gebäude, Arbeitsplätze und Schutzausrüstung.

- **ArGV 4:** Betrifft industrielle Betriebe und regelt insbesondere anwendbare Vorschriften sowie das Plangenehmigungsverfahren.
- **ArGV 5:** Schützt Gesundheit und Sicherheit von Jugendlichen bis zum 18. Altersjahr, etwa bei gefährlichen Arbeiten, Arbeitszeiten und Ruhezeiten.

Erklärungen:

- **Arbeitsgesetz (ArG):** Regelt den öffentlich-rechtlichen Arbeitnehmerschutz in Industrie, Gewerbe und Handel. Dazu gehören insbesondere Arbeitszeit, Pausen, Ruhezeiten, Nacht- und Sonntagsarbeit sowie Schutzbestimmungen.
- **Obligationenrecht (OR):** Enthält die privatrechtlichen Regeln zum Arbeitsvertrag, insbesondere Rechte und Pflichten von Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
- **Berufsbildungsgesetz (BBG):** Regelt die Berufsbildung und ist besonders für Lehrverhältnisse relevant.
- **Öffentlich-rechtliche Personalgesetze:** Gelten für Arbeitsverhältnisse im öffentlichen Dienst, z.B. kantonale Personalgesetze.
- **Arbeitsvermittlungsgesetz (AVG):** Regelt Arbeitsvermittlung und Personalverleih.
- **Datenschutzgesetz (DSG):** Schützt Personendaten, auch im Arbeitsverhältnis.
- **Gleichstellungsgesetz (GIG):** Fördert die tatsächliche Gleichstellung von Frau und Mann.
- **Mutterschutzverordnung:** Regelt den Schutz bei gefährlichen oder beschwerlichen Arbeiten während Schwangerschaft und Mutterschaft.
- **Mitwirkungsgesetz (MWG):** Regelt die Information und Anhörung der Arbeitnehmer in Betrieben.

1.3.1. Wichtige Artikel aus dem Arbeitsrecht

- **Art. 319 ff. OR:** Einzelarbeitsvertrag.
- **Art. 320 OR:** Formfreier Abschluss des Arbeitsvertrags, auch mündlich oder konkludent.
- **Art. 321 OR:** Persönliche Arbeitspflicht des Arbeitnehmers.
- **Art. 321a OR:** Sorgfalts- und Treuepflicht, inkl. Geheimhaltung.
- **Art. 321c OR:** Überstundenarbeit.
- **Art. 321d OR:** Befolgung von Anordnungen und Weisungen.
- **Art. 321e OR:** Haftung des Arbeitnehmers aus Vertragsverletzung.
- **Art. 322 ff. OR:** Lohnpflicht des Arbeitgebers.
- **Art. 323 OR:** Fälligkeit und Auszahlung des Lohns.
- **Art. 324 ff. OR:** Lohn bei Verhinderung der Arbeitsleistung.
- **Art. 324a OR:** Lohnfortzahlung bei Verhinderung des Arbeitnehmers.
- **Art. 328 OR:** Schutz der Persönlichkeit, Gesundheit und Integrität des Arbeitnehmers.
- **Art. 330a OR:** Anspruch auf Arbeitszeugnis.
- **Art. 332 OR:** Rechte an Erfindungen und Designs.
- **Art. 334 OR:** Ende des befristeten Arbeitsvertrags durch Zeitablauf.
- **Art. 335 ff. OR:** Ordentliche Kündigung.
- **Art. 335b OR:** Kündigung während der Probezeit.
- **Art. 335c OR:** Gesetzliche Kündigungsfristen.
- **Art. 336 ff. OR:** Missbräuchliche Kündigung.
- **Art. 336c OR:** Kündigung zur Unzeit / Sperrfristen.
- **Art. 337 ff. OR:** Fristlose Kündigung aus wichtigem Grund.
- **Art. 337a OR:** Fristlose Kündigung bei Insolvenz des Arbeitgebers.
- **Art. 337c OR:** Folgen ungerechtfertigter fristloser Kündigung.
- **Art. 338 OR:** Tod des Arbeitnehmers.
- **Art. 340 ff. OR:** Konkurrenzverbot.
- **Art. 344a OR:** Lehrvertrag.
- **Art. 347a OR:** Handelsreisendenvertrag.
- **Art. 351a OR:** Heimarbeitsvertrag.

- **Art. 356c OR:** Schriftform des Gesamtarbeitsvertrags.
- **Art. 361 OR:** Absolut zwingende arbeitsrechtliche Bestimmungen.
- **Art. 362 OR:** Relativ zwingende arbeitsrechtliche Bestimmungen.
- **Art. 3 lit. d ArG:** Leitende Arbeitnehmer sind dem Arbeitsgesetz nicht unterstellt.
- **Art. 9 ArG:** Beginn der Überzeit bei Überschreitung der gesetzlichen Höchstarbeitszeit.
- **Art. 162 StGB:** Verletzung von Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnissen.

1.4. Werkvertrag

- **Art. 363 OR:** Werkvertrag; Unternehmer erstellt oder verändert ein Werk gegen Vergütung.
- **Art. 365 OR:** Stofflieferung und Anzeigepflicht; Unternehmer muss auf untauglichen Stoff/Baugrund hinweisen.
- **Art. 366 OR:** Verzug oder mangelhafte Ausführung vor Ablieferung; Besteller kann zurücktreten oder Ersatzvornahme androhen.
- **Art. 367 und 370 OR:** Prüf- und Rügeobliegenheit; bei verspäteter Rüge gilt das Werk als genehmigt.
- **Art. 368 OR:** Mängelrechte; Wandelung, Minderung, Nachbesserung und ggf. Schadenersatz.
- **Art. 371 OR:** Verjährung der Mängelrechte; grundsätzlich 2 Jahre, bei unbeweglichen Werken bzw. Einbau in solche 5 Jahre.
- **Art. 373 OR:** Fixpreis; vereinbarter Werklohn bleibt grundsätzlich verbindlich.
- **Art. 374 OR:** Kein oder unklarer Preis; Werklohn nach Wert der Arbeit und Aufwand.
- **Art. 375 OR:** Überschreitung eines ungefähren Kostenansatzes; bei unverhältnismässiger Überschreitung Rücktritts-/Herabsetzungsrechte.
- **Art. 377 OR:** Rücktritt vor Vollendung; Besteller kann zurücktreten, muss aber Arbeit und Schaden ersetzen.

1.5. Auftrag

- **Art. 394 OR:** Einfacher Auftrag; Tätigwerden im fremden Interesse, Erfolg nicht geschuldet.
- **Art. 398 OR:** Sorgfalts- und Treuepflicht; getreue und sorgfältige Ausführung, Haftung bei Verschulden.
- **Art. 400 OR:** Rechenschafts- und Herausgabepflicht; Beauftragter muss Auskunft geben und Erlangtes herausgeben.
- **Art. 404 OR:** Jederzeitige Beendigung; Widerruf/Kündigung jederzeit möglich, bei Unzeit Schadenersatz.
- **Art. 406a OR:** Ehe- oder Partnerschaftsvermittlung gegen Vergütung.
- **Art. 412 OR:** Mäklervvertrag; Nachweis oder Vermittlung einer Vertragsgelegenheit gegen Vergütung.
- **Art. 418a OR:** Agenturvertrag; dauernde Vermittlung oder Abschluss von Geschäften ohne Arbeitsverhältnis.

1.6. Haftpflicht- und Produkterecht

- **Art. 41 OR:** Ausservertragliche Verschuldenshaftung; Schadenersatz bei widerrechtlicher, absichtlicher oder fahrlässiger Schädigung.
- **Art. 197 OR:** Sachgewährleistung beim Kauf; Verkäufer haftet für zugesicherte Eigenschaften und erhebliche körperliche oder rechtliche Mängel.
- **Art. 1 PrHG:** Grundsatz der Produkthaftpflicht; Hersteller haftet für Schäden durch fehlerhafte Produkte.
- **Art. 2 PrHG:** Haftpflichtige Personen; Hersteller, Importeur und unter Umständen Händler.
- **Art. 4 PrHG:** Fehlerhaftigkeit; Produkt ist fehlerhaft, wenn es nicht die berechnigte Sicherheit bietet.
- **Art. 6 PrHG:** Selbstbehalt; Sachschäden werden nur ersetzt, soweit sie CHF 900 übersteigen.

- **Art. 8 PrHG:** Haftungsbeschränkung gegenüber Geschädigten ist nichtig.
- **Art. 9 PrHG:** Verjährung; Ansprüche verjähren drei Jahre ab Kenntnis von Schaden, Fehler und haftpflichtiger Person.
- **Art. 10 PrHG:** Verwirkung; Anspruch erlischt spätestens zehn Jahre nach Inverkehrbringen des Produkts.

1.7. IT-Verträge

- **Art. 97 ff. OR:** Allgemeine Haftung bei Nichterfüllung oder Schlechterfüllung; wichtig, wenn kein spezieller Vertragstyp passt.
- **Art. 127 ff. OR:** Allgemeine Verjährungsregeln; relevant bei IT-Verträgen ohne besondere Verjährungsnorm.
- **Art. 160 ff. OR:** Konventionalstrafe; häufig bei Verletzung von Service Levels/SLA.
- **Art. 197 ff. OR:** Kaufrechtliche Gewährleistung; relevant bei Standardsoftware, Hardware oder kaufvertraglichen Elementen.
- **Art. 363 ff. OR:** Werkvertragsrecht; relevant, wenn ein bestimmter Erfolg geschuldet ist, z.B. Softwareentwicklung oder Systemeinführung.
- **Art. 394 ff. OR:** Auftragsrecht; relevant bei Beratung, Planung, Projektleitung oder nicht erfolgsbezogenen IT-Dienstleistungen.
- **Art. 41 OR:** Ausservertragliche Haftung; Schadenersatz bei widerrechtlicher Schädigung.
- **Art. 55 OR:** Geschäftsherrenhaftung; Haftung für Hilfspersonen/Angestellte.
- **Art. 321e OR:** Haftung des Arbeitnehmers; relevant bei arbeitsrechtlichen Ansprüchen im IT-Kontext.
- **PrHG:** Produkthaftung; relevant bei fehlerhafter Software/Hardware, soweit ein Produkt im Sinne des PrHG vorliegt.

2. Obligationenrecht - Erklärungen

2.1. Entstehung einer Obligation

- Vertrag (Art. 1 - 40 ff. OR)
- unerlaubte Handlungen (Art. 41-61 OR)
- ungerechtfertigte Bereicherung (Art. 62-67 OR)

andere Rechtsgründe:

- Geschäftsführung ohne Auftrag (Art. 419 ff. OR)
- Culpa in contrahendo
- Eigentumsfreiheitsklage (Art. 641 ZGB)
- Besitzesrechtsklage (Art. 934 ff. ZGB)
- Persönlichkeitsverletzung (Art. 28 ff. ZGB)
- Verwandtenunterstützungspflicht (Art. 328 f. ZGB)

2.2. Rechtssubjekte (Personen)

Natürliche Personen: Menschen

Juristische Personen:

- AG (Art. 620 ff. OR)
- GmbH (Art. 772 ff. OR)
- Genossenschaft (Art. 828 ff. OR)
- Verein (Art. 60 ff. ZGB)
- Stiftung (Art. 80 ff. ZGB)

Merke: Die Kollektiv- und Kommanditgesellschaften sind keine juristischen Personen, sondern Rechtsgemeinschaften. Im Rechtsverkehr treten diese Gesellschaften trotzdem unter eigener Firma auf. Die Kollektiv- und Kommanditgesellschaften sind unter ihrer Firma parteifähig und damit prozess- und betreibungsfähig (vgl. Art. 562 OR).

2.3. Culpa in contrahendo

Culpa in contrahendo: Schuldhaftes Verletzung vorvertraglicher Pflichten, wobei eine allfällige Schadenersatzpflicht unabhängig davon eintreten kann, ob der Vertrag in der Folge gültig zustande kommt oder nicht. Grundlage ist Art. 2 Abs. 1 ZGB.

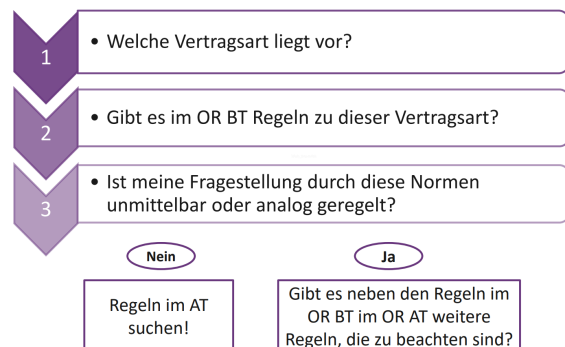
2.4. Verträge

AT = Allgemeiner Teil, Art. 1 bis 183 OR

- Allg. regeln im OR (Vertragsschluss, Willensmangel etc.)

BT = Besonderer Teil, ab Art. 184 OR

- Vertragsarten (Kaufvertrag, Mietvertrag etc.)



2.4.1. Grundsatz der Vertragsfreiheit (Art. 19 OR)

Parteien können den Vertragsinhalt grundsätzlich frei bestimmen. Grenzen sind zwingendes Recht, öffentliche Ordnung, gute Sitten und Persönlichkeitsrechte.

Verschiedene Aspekte:

- Abschlussfreiheit
- Partnerwahlfreiheit
- Inhaltsfreiheit
- Aufhebungsfreiheit
- Formfreiheit

Vertragsfreiheit: Tatsächliche Gültigkeit eines Vertrages hängt von verschiedenen Voraussetzungen ab.

2.4.2. Voraussetzungen für Verträge

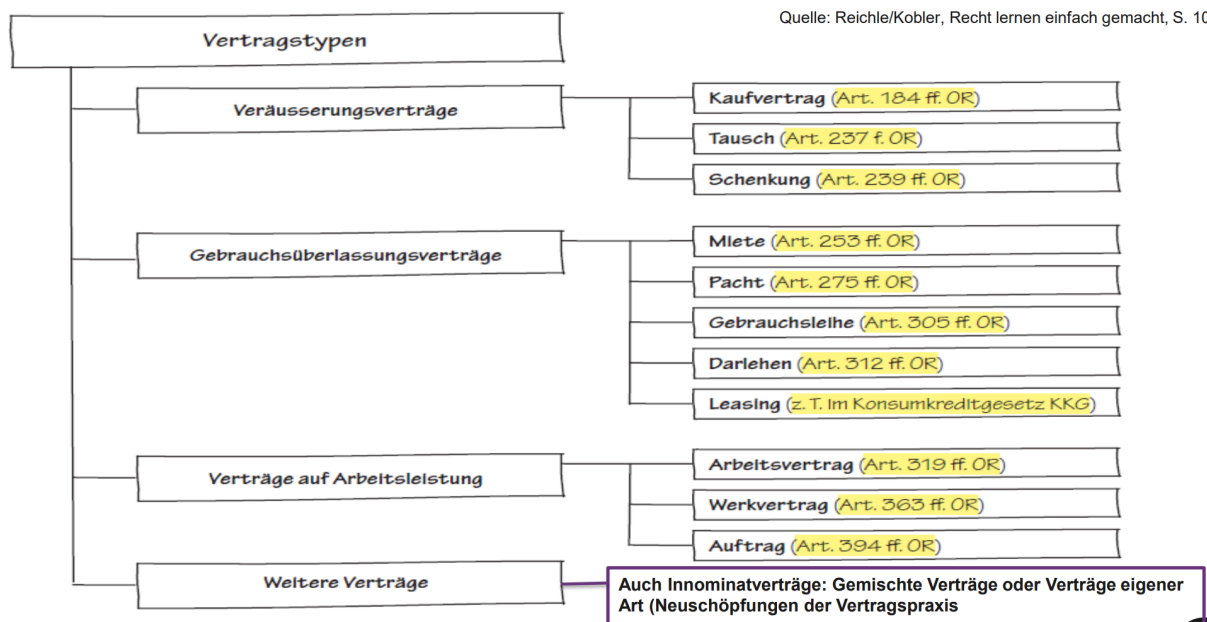
- (beschränkte) Handlungsfähigkeit der Parteien
- Konsens beim Vertragsabschluss
- Formgültigkeit
- Kein Inhaltsmangel: nicht unmöglich, nicht rechtswidrig (z.B. Verstoss der AGB gegen UWG 8), nicht unsittlich
- Kein Willensmangel
- Gültige Stellvertretung

2.4.3. Gesetzliche Bestimmungen

Dispositive Gesetzesbestimmungen: Sofern der Vertrag Aspekte nicht regelt, kommen die dispositiven Gesetzesbestimmungen zum Zuge. Die meisten Bestimmungen im OR AT und im OR BT sind dispositiv und finden bloss Anwendung, wenn die Parteien nichts anderes vereinbart haben.

Zwingende Gesetzesbestimmungen: Die zwingenden Gesetznormen gehen den vertraglichen Bestimmungen immer vor. Beispiele: OR 100 I, OR 199, OR 210 IV, OR 404, UWG 8 – sodann zahlreiche Normen des Miet- und Arbeitsrechts.

2.4.4. Vertragstypen



2.4.5. Formvorschriften

Gründe:

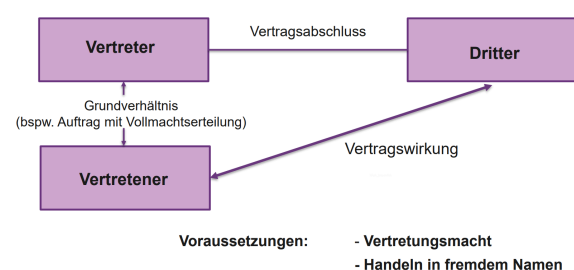
1. Beweissicherung
2. Schutz vor übereilem Vertragsschluss
3. Rechtssicherheit
4. Schutz der schwächeren Partei

2.4.6. Vertragsform

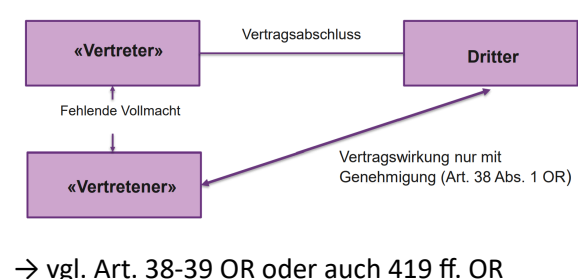
Vertragsform	Merkmale	Beispiele
Formfreiheit (Art. 11 OR)	Das Obligationenrecht geht von dem Grundsatz der Formfreiheit aus. Darunter versteht man die Freiheit, Verträge in freier Form abzuschliessen, abzuändern oder aufzuheben. Eine besondere Form ist nur notwendig, wenn es das Gesetz oder die Abrede eine solche vorschreibt.	• Einzelarbeitsvertrag • Mietvertrag • Kaufvertrag • Darlehen
Einfache Schriftlichkeit (Art. 13–15 OR)	Ist die einfache Schriftlichkeit vorgesehen, muss der Vertrag die eigenhändige Unterschrift oder eine qualifizierte elektronische Signatur aller beteiligten Personen aufweisen.	• Schenkungsversprechen • Lehrvertrag • Versicherungsvertrag • Konkurrenzverbot im Arbeitsvertrag
Qualifizierte Schriftlichkeit	Die qualifizierte Schriftlichkeit verlangt nicht nur die Unterschrift der Verpflichteten, sondern die handschriftliche Angabe gewisser Elemente in der Urkunde.	• Bürgschaft • Testament
Öffentliche Beurkundung	Bei der öffentlichen Beurkundung erfolgt der Vertragsschluss unter Mitwirkung einer Urkundsperson, z. B. Notar. Die Urkundsperson bestätigt die Richtigkeit des Inhaltes der Urkunde.	• Grundstückkaufvertrag • Vorvertrag über ein Grundstück mit Kaufpreis • Bürgschaft natürlicher Personen, wenn die Haftungssumme über Fr. 2'000.– liegt • Ehe- und Erbvertrag

2.4.7. Stellvertretung

Mit Ermächtigung



Ohne Ermächtigung



Merke: Die Erklärung des Vertreters, in fremdem Namen zu handeln kann entweder ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen, gemäss Art. 32 Abs. 2 OR genügt es, dass der Dritte aus den Umständen auf das Vertretungsverhältnis schliessen muss (Z. Bsp. Angestellter in einem Einkaufsgeschäft)

Arten von Vollmachten: Spezialvollmacht, Generalvollmacht und Gattungsvollmacht, Einzel- und Kollektivvollmacht

Sog. Unechte Stellvertretung: Handeln für fremde Rechnung, aber in eigenem Namen, siehe Art. 32 Abs. 3 OR

2.4.8. Vertragsschluss (Art. 1 OR)

Ein Vertrag entsteht durch übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung. Diese kann ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen.

Willensäusserung: Angebot und Annahme.

Antrag: Der Antrag ist ein einseitiges Rechtsgeschäft, der auf den Abschluss eines Vertrages gerichtet ist. Begrifflichkeiten:

- Empfangsbedürftigkeit
- Unterscheidung verbindlicher - und unverbindlicher Antrag (vgl. Art. 7 OR)
- Widerruf (Art. 9 OR)

Annahme: Die Annahme ist ein einseitiges Rechtsgeschäft. Begrifflichkeiten:

- Einverständnis in den wesentlichen Punkten («essentialia negotii»)
- Art. 2 OR: Einigung über alle wesentlichen Punkte genügt, offene Nebenpunkte hindern die Verbindlichkeit grundsätzlich nicht
- Empfangsbedürftigkeit
- Stillschweigende Annahme (Art. 6 OR)
- Widerruf (Art. 9 OR)
- Widerruf beim Haustürgeschäft (Art. 40a ff. OR)

2.4.8.1. Ausdrückliche Willensäusserung

Beispiele:

- mündlich
- schriftlich per Brief, E-Mail, SMS
- durch Gesten

Rechtsgrundlage: Art. 1 Abs. 2 OR

2.4.8.2. Konkludente Willensäusserungen

Stillschweigen

Grundsatz: **keine** Willensäusserung.

Ausnahmen (Stillschweigen = Willensäusserung) betreffen unter anderem Art. 6 OR.

Beispiele:

- Wer noch nicht verfallene Mietzinse stillschweigend entgegennimmt, stimmt implizit einer Verlängerung der Miete zu.
- Beauftragung eines Anwalts (Art. 395 OR)

Beispiele weiteres schlüssiges Verhalten

- wortloses Hinlegen von Waren auf das Beförderungsband an der Kasse
- wortloses Hinlegen des Kaufpreises am Kiosk
- Einwurf von Münzen am Getränkeautomaten zum Kauf eines Süssgetränks

Rechtsgrundlage: Art. 1 Abs. 2 OR

2.4.9. Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB's)

Begriff

- generell vorformulierte Bestimmungen, die Inhalt des Vertrages werden
- gelten für eine Vielzahl von Verträgen
- Abweichungen vom dispositiven Recht

Geltung

nur verbindlich, wenn von den Parteien übernommen, d. h. keine allgemeine Verbindlichkeit

Keine Geltung, trotz Übernahme

- Verstoß gegen zwingendes Recht
- abweichende individuelle Regelung
- keine Möglichkeit, sich vom Inhalt Kenntnis zu verschaffen
- ungewöhnliche Klausel
- missbräuchlicher Inhalt (Art. 8 UWG)

Auslegung

bei Unklarheiten gegen den Verfasser

2.4.10. Erfüllung der Obligation

Eine Obligation erfüllen heisst, die geschuldete Leistung richtig, mängelfrei und rechtzeitig zu erbringen.

Wichtige Einzelpunkte der Erfüllung:

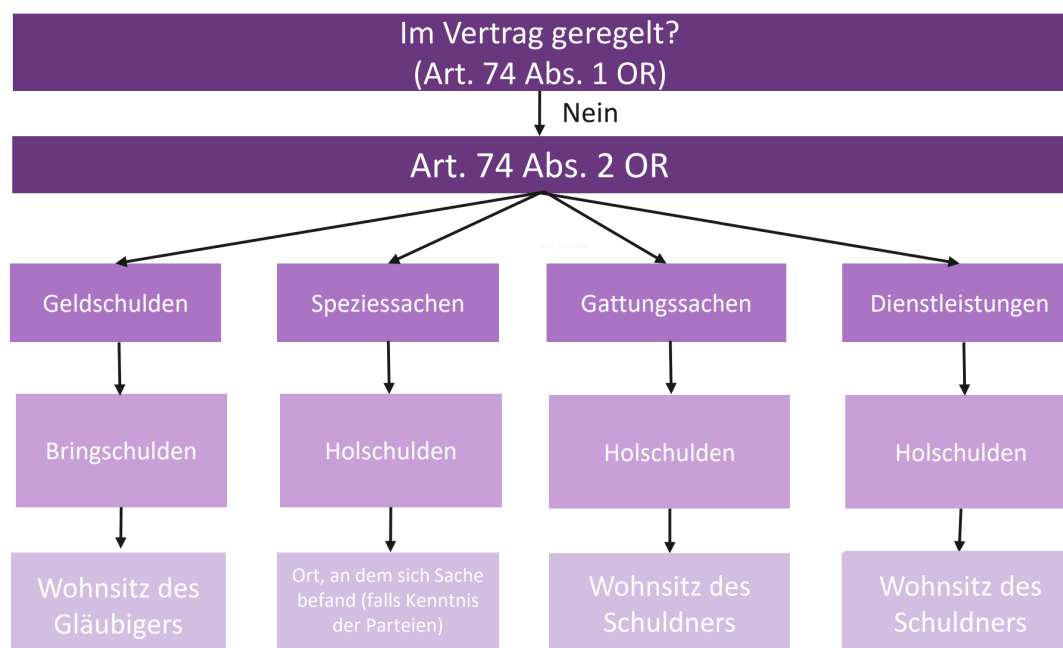
- Person des Erfüllenden (vgl. OR 68, 321, 364 II, 398 III)
- Gegenstand (vgl. OR 2 I)
- Ort der Erfüllung (vgl. OR 74, 189 I)
- Zeit der Erfüllung (vgl. OR 75, 213 I, 257c, 318, 323 I, 372 I)

Die meisten Erfüllungsregeln des Allgemeinen Teils des OR gelten nur:

- wenn die Parteien keine abweichenden Vereinbarungen getroffen haben
- wenn die Vorschriften des Besonderen Teils des OR keine abweichenden Regelungen enthalten

Grundsatz: spezielles Recht geht allgemeinem Recht vor.

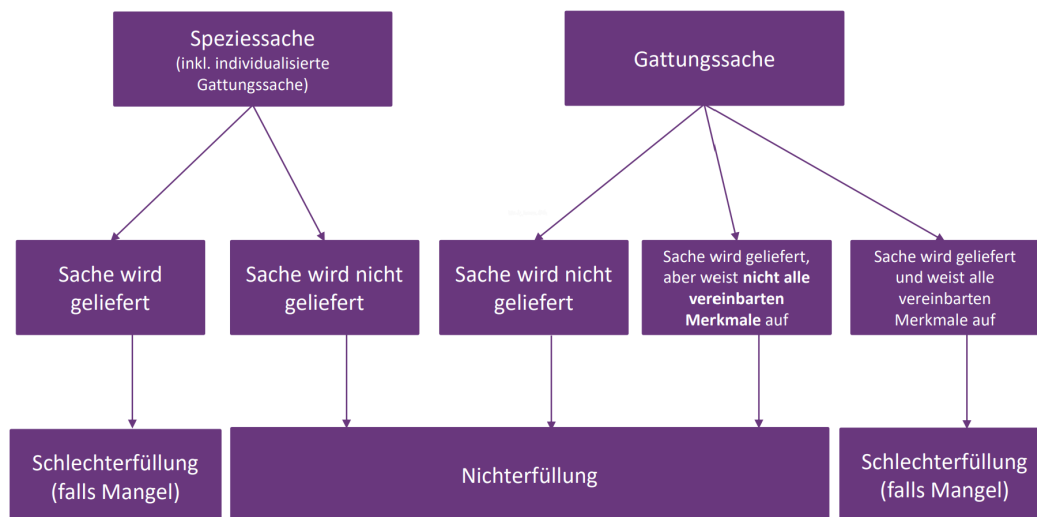
2.4.10.1. Ort der Erfüllung

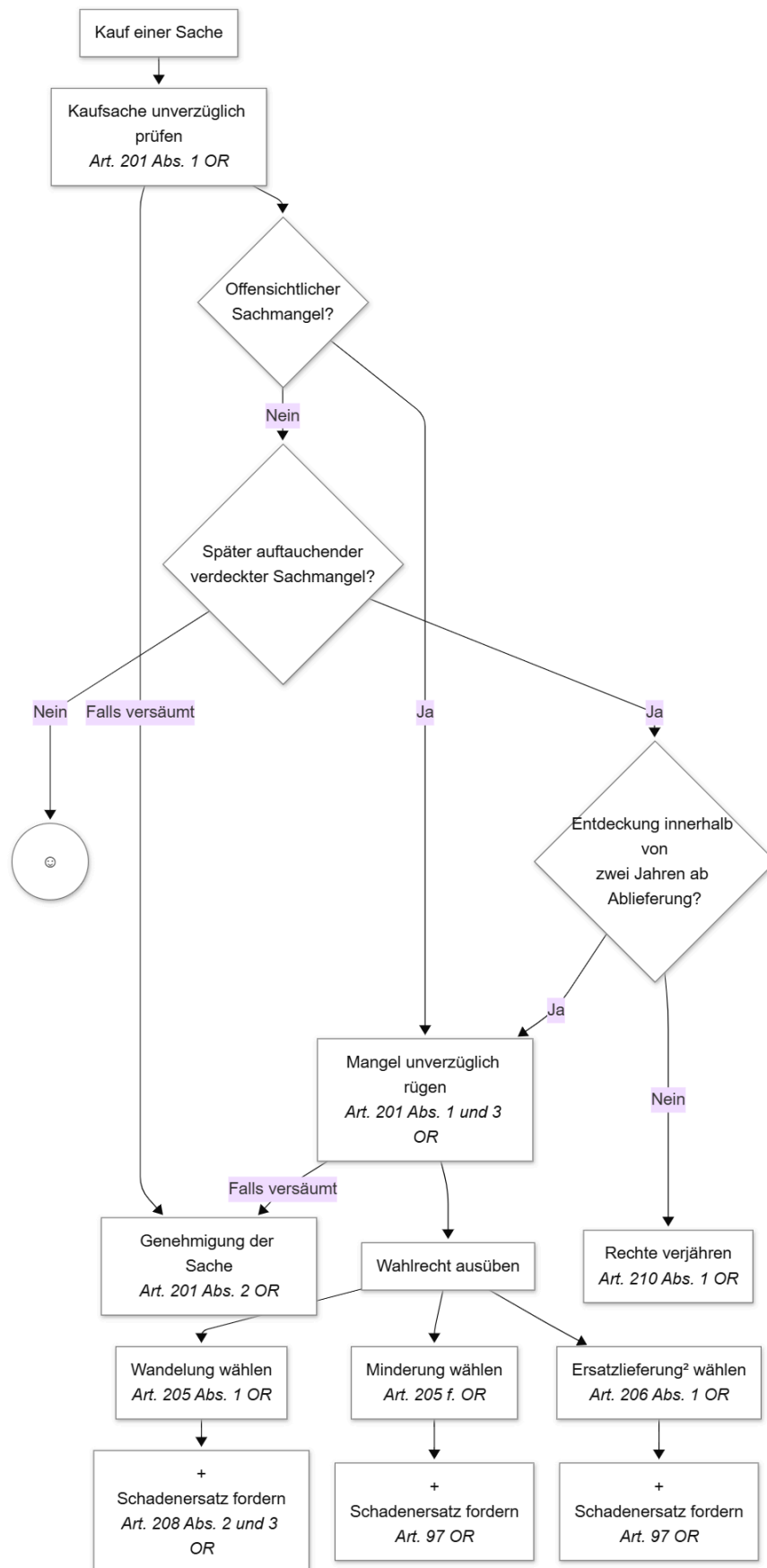


2.4.10.2. Erfüllungsstörungen

Auf Seiten des Schuldners	Auf Seiten des Gläubigers
Nichterfüllung (Art. 97 ff. OR)	Gläubigerverzug (Art. 91 ff. OR) → Unterlassung von Mitwirkungshandlungen
Positive Vertragsverletzung (Art. 97 ff. OR) → Verletzung von Nebenpflichten oder Schlechterfüllung	
Schuldnerverzug (Art. 102 ff. OR)	

Merke: Für den Schuldner besteht Erfüllungszwang. Art. 98 OR gibt dem Gläubiger die Möglichkeit, sich vom Richter zur ersatzweisen Vornahme der ausgebliebenen Leistung ermächtigen zu lassen. Der Gläubiger kann natürlich auch auf Erfüllung klagen.





2.4.10.3. Schuldnerverzug anhand des Kaufvertrages

Der Schuldner gerät in Verzug, wenn eine fällige Forderung trotz Mahnung oder Verfalltag nicht erfüllt wird und keine verzugshindernden Gründe vorliegen.

2.4.10.4. Ablauf

1. Forderung wird fällig
 - Normalfall: Mahnung
 - Ausnahme: Nach OR 102 II tritt Verzug ohne Mahnung ein, z. B. bei einem bestimmten Verfalltag.
2. Verzug
3. Verzugsfolgen

2.4.10.5. Voraussetzungen

- Nichtleistung trotz Fälligkeit
- Fälligkeit der Forderung
- Mahnung oder Verfalltag
- keine verzugshindernden Gründe

2.4.10.6. Verzugsfolgen

verschuldensunabhängig

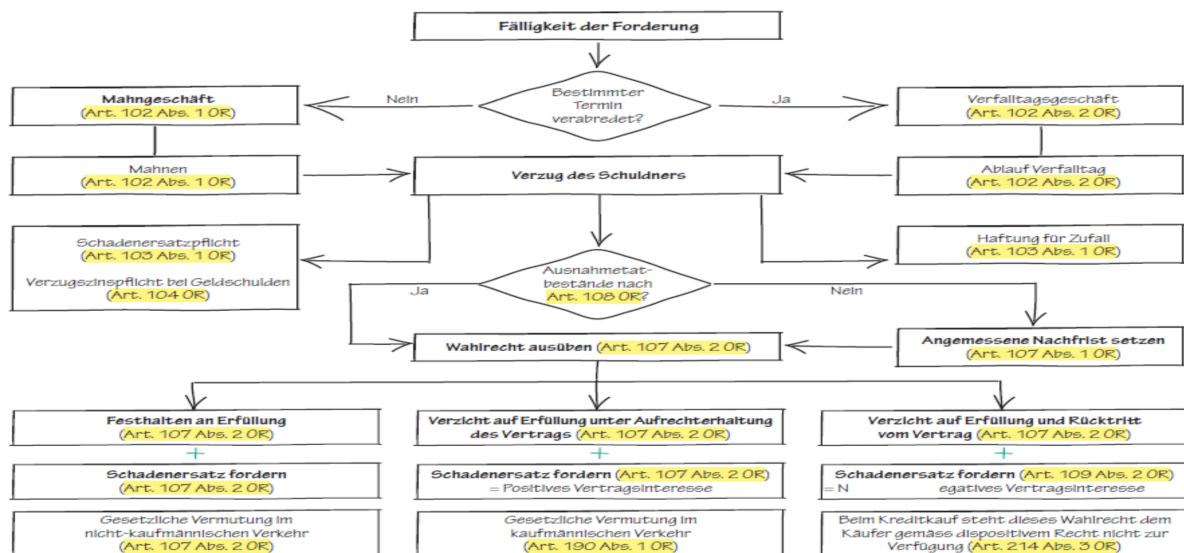
- Geldschulden: Verzugszins
- Bei zweiseitigen Verträgen: Rücktritt und Rückforderung bereits erbrachter Leistungen

verschuldensabhängig

Schadenersatzpflichten:

- Verzugschaden und Unfallhaftung (Art. 103 OR)
- bei Verzicht auf Leistung (Art. 107 Abs. 2 OR)
- bei Rücktritt (Art. 109 Abs. 2 OR)

2.4.10.7. Zusammenfassung Verzug



2.4.10.8. Erfüllungszeit

Eine Obligation entsteht mit dem Vertragsschluss. Ab diesem Zeitpunkt gibt es die Forderung grundsätzlich bereits.

Nach Art. 75 OR gilt ohne andere Vereinbarung:

- Der Gläubiger darf die Leistung sofort fordern. Das ist die **Fälligkeit**.
- Der Schuldner darf grundsätzlich sofort leisten. Das ist die **Erfüllbarkeit**.

Wird ein bestimmter Termin vereinbart, kommt es auf die Formulierung an:

- „Wir liefern Ihnen am 12. Juni 2019“
 - Die Leistung ist genau an diesem Tag zu erbringen. Der Schuldner muss an diesem Zeitpunkt leisten.
- „Wir liefern Ihnen bis zum 21. August 2019“
 - Der Schuldner darf vorher leisten, muss aber spätestens bis zu diesem Datum leisten. Der Gläubiger darf die Leistung ab diesem Zeitpunkt verlangen.
- Ohne Termin: „Wir liefern Ihnen 5000 l Heizöl“
 - Fälligkeit und Erfüllbarkeit beginnen grundsätzlich sofort nach Vertragsschluss.

Kurz gesagt: **Erfüllbarkeit** bedeutet, ab wann der Schuldner leisten darf oder muss. **Fälligkeit** bedeutet, ab wann der Gläubiger die Leistung verlangen darf.

2.4.11. Übersicht Inhalts-/Willensmangel

Inhaltsmangel: Der Vertragsinhalt verstösst gegen gesetzliche Schranken oder ist objektiv unmöglich.

Rechtsfolge:

- grundsätzlich Nichtigkeit des Vertrags (Art. 20 OR)
- betrifft der Mangel nur einzelne Teile: Teilnichtigkeit möglich (Art. 20 Abs. 2 OR)

Typische Fälle:

- widerrechtlicher Vertragsinhalt
 - ewige Verträge ohne Kündigungsmöglichkeiten
 - Kaufvertrag über 5g Kokain
- sittenwidriger Vertragsinhalt
 - Prostitutionsvertrag
 - Bezahlte Unterstützung der Erbschleicherei
- anfänglich objektiv unmöglicher Vertragsinhalt

Willensmangel: Der Vertrag kommt zwar zustande, der Wille einer Partei ist aber mangelhaft gebildet oder beeinflusst.

Rechtsfolge:

- Vertrag ist anfechtbar
- Anfechtbarkeit nach Art. 21 und Art. 23 ff. OR

Typische Fälle:

- Übervorteilung (Art. 21 OR)
- wesentlicher Irrtum (Art. 23 f. OR)
- absichtliche Täuschung (Art. 28 OR)
- Drohung oder Furchterregung (Art. 29 f. OR)

Merke: Inhaltsmängel betreffen den Inhalt des Vertrags und führen grundsätzlich zur Nichtigkeit. Willensmängel betreffen die Willensbildung einer Partei und führen grundsätzlich zur Anfechtbarkeit.

2.4.12. Wesentlicher Irrtum

Grundlagenirrtum: (Willensbildung)

- Wirklicher Wille = Erklärter Wille
- Jedoch fehlerhafte Willensbildung
- (Irrtum über eine notwendige Vertragsgrundlage)
- Art. 24 Abs. 1 Ziff 4 OR

Voraussetzungen Grundlagenirrtum:

- subjektive Wesentlichkeit
- objektive Wesentlichkeit
- Erkennbarkeit des Irrtums für Gegenpartei

Erklärungsirrtum: (Willenserklärung)

- Wirklicher Wille != Erklärter Wille

- (Irrtümliche Erklärung über Vertragsart, Vertragsgegenstand/Person, Umfang der Leistung)
- Kommunikationsfehler (Verschreiber, Versprecher etc.)
- Art. 24 Abs. 1 Ziff 1-3 OR

2.4.13. Verjährung

Begriff: Untergang der Durchsetzbarkeit einer Obligation durch Zeitablauf

Fristen: Grundsatz: OR 127

Ausnahmen: OR 128, OR 128a, OR 60, OR 67 etc.

Merke: Gesetzliche Verjährungsfristen können vertraglich nicht abgeändert werden, aber es besteht die Möglichkeit, auf die Verjährungseinrede zu verzichten.

- Beginn mit Fälligkeit der Forderung (vgl. OR 130, OR 60/67)
- Unterbrechung = Neubeginn der Verjährung
 - durch Schuldner: Anerkennung
 - durch Gläubiger: Betreibung, Klage, Eingabe im Konkurs

Merke: Verjährung wird nicht von Amtes wegen berücksichtigt, sondern nur auf Einrede

2.4.13.1. Beispiele

Wesentliche vertragliche Verjährungsfristen:

- **Art. 127 OR:** 10 Jahre (generell)
- **Art. 128 OR:** 5 Jahre (Miet-, Pacht-, und Kapitalzinse, Lieferung von Lebensmittel, Handwerksarbeit etc)
- **Art. 210 OR:** 2 und 5 Jahre bei Kaufgewährleistung
- **Art. 371 OR:** 2 und 5 Jahre bei Werkgewährleistung
- Die kurzen Gewährleistungsfristen gelten nicht bei absichtlicher Täuschung.

2.4.14. Beispiele

Fall	Lösung
Vertraglicher Schadenersatzanspruch aus OR 97	10 Jahre nach Art. 127 OR, da keine kürzere Spezialfrist gilt.
Ausstehende Kaufpreisforderung für Kauf von Kleinwaren	5 Jahre nach Art. 128 Ziff. 3 OR.
Ausstehende Mietzinszahlungen	5 Jahre nach Art. 128 Ziff. 1 OR.
Susis Gewährleistungsrechte für das gekaufte Elektrogerät	2 Jahre nach Art. 210 Abs. 1 OR.
Susis Gewährleistungsrechte für das erworbene Ferienhaus	5 Jahre, da es sich um ein Grundstück bzw. eine Immobilie handelt.
Pablos Rechnung von CHF 3'000 für den Bau der Veranda	5 Jahre nach Art. 128 Ziff. 3 OR, da es sich um Handwerksarbeit handelt.
Anitas Gewährleistungsrechte wegen der Veranda	5 Jahre nach Art. 371 OR, da es sich um ein unbewegliches Werk handelt.

2.5. Erlöschen der Obligation

Eine Obligation erlischt, wenn der Schuldner die Leistung erbracht hat oder nicht mehr erfüllen muss. Der Gläubiger kann die Leistung dann nicht mehr verlangen oder durchsetzen.

Art des Erlöschens	Rechtsgrundlage
Erfüllung	Normalfall
Verrechnung	OR 120-126
Verjährung	OR 127-142
Aufhebung	OR 115
Neuerung	OR 116-117
Vereinigung	OR 118
Nachträgliche Unmöglichkeit	OR 119

Erlöschen heisst:

- Schuldner hat Leistung erbracht oder muss nicht mehr erfüllen
- Gläubiger kann Leistung nicht mehr verlangen oder durchsetzen

3. IT-Verträge

3.1. Eigenschaften

- **Inominatverträge** (Vertrag, der keinem gesetzlich geregelten Vertragstyp entspricht) und enthalten oft Elemente des Auftrags/Werkvertrags
- Kann auch Elemente von Miet, Hinterlegung, Pacht oder Kaufvertrag beinhalten
- Abgrenzung ist schwierig und muss von Fall zu Fall angeschaut werden -> wichtig genau zu formulieren

Beispiele:

- Software Entwicklung: Erfolg ist geschuldet -> Werkvertrag
- Nutzungsrechte bei Cloudverträgen: Können Elemente der Miete enthalten
- Planung, Beratung, Projektleitung: Auftrag
- Erwerb einer Standardsoftware: Kaufvertrag

Wo die Bestimmungen des OR BT nicht oder nur beschränkt angewendet werden können, kommen die OR AT-Bestimmungen (z.B. Folgen der Nichterfüllung OR 97ff. oder Verjährung OR 127ff.) zum Tragen.

3.2. Erscheinungsformen

Wichtige IT-Verträge:

- **Software-Lizenzvertrag:** Einräumung von Rechten zum Gebrauch von Applikationen während längerer Dauer, gegen die Entrichtung von Benützungsgebühren. Bspw. unbefristete Lizenzierung, Abonnement-basierte Lizenzierung (Spotify, Adobe, Netflix), Netzwerklizenzen, Cloudbasierte Lizenzierung
- **Wartungsvertrag:** Vertragsgegenstand ist der Erhalt/Verbesserung und/oder die Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft der Software oder die Aktualisierung, Beratung sowie Pflege der Software.
- **Dienstleistungsvertrag für Planung und Beratung**
- **Lieferung von integrierten Informatiksystemen**
- **Systemintegrationsvertrag:** Planung, Einrichtung und Aufbau von IT-Systemen. Prüfung von Kompatibilität von Hardware- und Softwarekomponenten
- **IT-Werkvertrag:** Es ist ein bestimmbares oder bestimmtes Ergebnis geschuldet. Das Werk muss genau, auch für Dritte nachvollziehbar, umschrieben und definiert werden.
- **IT-Dienstleistungsvertrag:** Der Beauftragte verpflichtet sich, für den Kunden in fachgerechter Sorgfalt tätig zu werden, nicht aber zur Realisierung eines bestimmten Erfolges.
- **Outsourcingvertrag:** Outside Resource Using, Auslagerung von IT-Systemen oder Prozessen
- **Software Escrow Agreement:** Entwickler hinterlegt den Source Code von Software bei einem neutralen Dritten. Der Escrow-Agent bewahrt den Source Code sicher auf. Erst wenn eine der vordefinierten Voraussetzungen eintritt, gibt der Escrow-Agent dem Kunden den Source Code heraus.
- **Cloud Services:**
 - Infrastructure as a Service (IaaS) = Bereitstellung von Speicher, Netzwerk, Servern und Virtualisierung (Bspw. IBM Cloud, Google Compute Engine, Amazon Web Services und Microsoft Azure)
 - Software as a Service (SaaS) = Lizenz- und Vertriebsmodell, mit dem Software-Anwendungen über das Internet, d.h. als Service, angeboten werden. Die Nutzung erfolgt in der Regel auf Abonnementbasis. SaaS wird auf Remote-Servern betrieben und vom Anbieter verwaltet, aktualisiert und gewartet. (Bspw. Dropbox, Microsoft Office oder Google Apps)

- Platform as a Service (PaaS) = Plattform kann über das Internet genutzt werden und bietet Nutzern sowohl ein Framework als auch passende Tools, um Applikationen und Software zu entwickeln. (Bspw. Windows Azure, SAP Cloud oder Google App Engine)
- **Hardwareverkaufsvertrag**
- **Softwareentwicklungsvertrag:** Entwickler erstellt eine Software-Applikation nach den konkreten Vorgaben des Bestellers
- **Roamingverträge:** Nutzung des mobilen Endgerätes in einem ausländischen Netz für Telefonate, Nachrichten und mobile Daten
- **Software-Distributionsvertrag:** Hersteller oder Lieferant beauftragt einen Vertreiber mit dem Verkauf seiner Produkte
- **Hosting-Dienstleistungen:** Überlassung von Speicherplatz auf der Serverinfrastruktur des Anbieters für die Website oder Applikation des Kunden sowie die Erbringung dazugehöriger Dienstleistungen.
- **Konzeption/Realisierung einer Web-Applikation:** Softwareprogramm, das auf einem Webserver ausgeführt wird. Im

Gegensatz zu Desktop-Anwendungen, die lokal auf einem Computer installiert werden, muss auf Webanwendungen über einen Webbrowser zugegriffen werden. Bspw. Webshop oder Internet-Banking Programme, Evernote, Google Apps, Pocket.

- **Erstellen einer Website**

3.3. Leistungsstörungen

Mögliche Leistungsstörungen:

- IT-System funktioniert nicht wie erwartet
- Softwarefehler führen zu Systemausfällen und Datenverlusten
- Anfälligkeit des Systems auf Hackerangriffe
- Systemzugriffe sind nicht möglich
- Prozesse laufen nicht wie vorgesehen ab

Konsequenzen:

- Produktionsausfälle (Einnahmeverlust, Schadenersatzansprüche von Vertragspartnern, weitere mittelbare Schäden)
- Personenschäden bei Systemausfällen/Fehlsteuerung von sicherheitsrelevanter Software
- Reputationsschäden
- Persönlichkeits- und Datenschutzverletzungen

Mögliche Haftungsansprüche:

- Ausservertragliche Haftungsansprüche (z.B. Delikt- (OR 41), Geschäftsherren- (OR 55) und Produkthaftung (PrHG))
- Vertragliche Haftungsansprüche (z.B. Arbeitsrechtliche Ansprüche (OR 321e), Gewährleistungs- und Haftungsansprüche (z.B. OR 97))
- Verantwortlichkeitsansprüche

3.4. Mängelrechte

Bei Mängeln ist jeweils darauf zu achten, welche rechtlichen Grundlagen am ehesten zur Anwendung kommen, sofern die Parteien diesbezüglich nichts vereinbart haben:

- Mängel und Verzug bei:
 - **kaufvertraglichen Eigenschaften** s. Art. 97ff. OR und die besonderen Bestimmungen zum Kaufvertrag insb. Art. 197ff. OR (Wandelung, Minderung oder Ersatzlieferung)
 - **werkvertraglichen Eigenschaften** s. Art. 97ff. OR und die besonderen Bestimmungen zum Werkvertrag Art. 363ff. OR (Wandelung, Minderung oder Nachbesserung)
 - **auftragsrechtlichen Eigenschaften** s. Art. 97ff. OR und die besonderen Bestimmungen zum Auftrag Art. 394ff. OR (Schadenersatz)

3.5. Risiken/Probleme

- Uneinigkeit betreffend der zu erbringenden Leistung
- Mangelhafte Vertragserfüllung (Nichterfüllung/Schlechterfüllung)
- Haftung
- Datenschutzverletzungen
- Sich verändernde Bedürfnisse des Leistungsnachfragers
- Höhere Kosten als erwartet/veranschlagt
- Ausstehende Zahlungen
- Vorzeitige Vertragsauflösung

3.6. Regelungspunkte

3.6.1. Leistung und Preis

- Leistung genau umschreiben, z.B. Pflichtenheft, Termine und Mitwirkungspflichten
- Preis klar regeln, inkl. Berechnungsart, Zusatzleistungen und Preisanpassungen

3.6.2. Nutzung und Lizenzen

- Nutzungsrechte festlegen, besonders Dauer, Umfang, Weiterverwendung und Migration
- Lizenzverträge prüfen, auch Lizenzen von Drittanbietern

3.6.3. Datenschutz und Geheimhaltung

- Datenschutz und Informationssicherheit regeln, z.B. Personendaten und Sicherheitsstandard des Providers
- Geheimhaltung für vertrauliche Geschäfts- und Projektdaten vereinbaren

3.6.4. Mängel, Gewährleistung und Haftung

- Gewährleistung und Haftung klären: Wer haftet wofür und in welchem Umfang
- Mängel definieren, z.B. fehlende Funktionen, schlechte Performance, fehlende Lizenzen, Viren oder fehlende zugesicherte Eigenschaften
- Mängelmeldeprozess und Abgrenzung zu kostenpflichtigem Support festlegen

3.6.5. Vertragsende

- Vertragsauflösung regeln, ordentlich und ausserordentlich

3.7. Mögliche Vertragsklauseln

3.7.1. Gewährleistung und Abnahme

- **Grundsatz:** Anbieter schuldet sorgfältige Leistung und vereinbarte Funktionen
- **Software/Hardware:** Eigene Software, Hardware und Fremdsoftware oft nach separaten Lizenz- oder Garantiebestimmungen
- **Abnahme:** Nach Leistungserbringung; Abnahmeprotokoll nur bei Vereinbarung
- **Wartung:** Nach Abnahme separat regeln
- **Mängelrüge:** Schriftlich und fristgerecht, z.B. während Projekt oder innert 30 Tagen nach Rechnung
- **Mangel:** Wesentliche Abweichung von Spezifikation, Vertrag oder Programmbeschrieb
- **Kostenlose Mängelbehebung:** Anerkannte Mängel kostenlos beheben
- **Kostenpflichtige Mängelbehebung:** Wenn Mangel nicht vom Anbieter zu vertreten ist
- **Aus Bestellersicht:** Abnahmeverfahren, Prüffristen, Mängelkategorien und Nachbesserungsrechte klarer regeln

3.7.2. Haftung

- **Voraussetzungen:** Anbieter haftet oft nur bei rechtswidriger Absicht oder grober Fahrlässigkeit

- **Haftungsbegrenzung:** Häufig auf jährliche Zahlungen oder geschuldete Entgelte begrenzt
- **Folgeschäden:** Mittelbare Schäden, entgangener Gewinn und Ansprüche Dritter werden oft ausgeschlossen
- **Haftungsausschluss:** Möglich bei Eingriffen Dritter, Änderungen durch Kunden oder mangelhafter Mitwirkung
- **Leistungsverhinderung:** Keine Haftung bei Gründen ausserhalb der Verantwortung des Anbieters
- **Aus Bestellersicht:** Haftung nicht zu stark beschränken, Datenschutz-/IP-Verletzungen und grobe Pflichtverletzungen ausnehmen

3.8. Outsourcingvertrag

- Auslagerung von IT-Infrastruktur, Anwendungen oder Geschäftsprozessen an einen externen Provider
- Rechtlich oft kein gesetzlich geregelter Vertragstyp, sondern Inominatvertrag bzw. gemischter Vertrag
 - Kann Elemente von Miete, Pacht, Werkvertrag oder Auftrag enthalten.
- Erscheinungsformen:
 - **Systems Management:** Provider stellt/betreibt IT-Infrastruktur, Nutzer erledigt Aufgaben selbst.
 - **Application Management:** Provider betreut eine Softwareanwendung.
 - **Business Process Outsourcing:** Provider übernimmt zusätzlich Geschäftsprozesse des Kunden.

Vorteile:

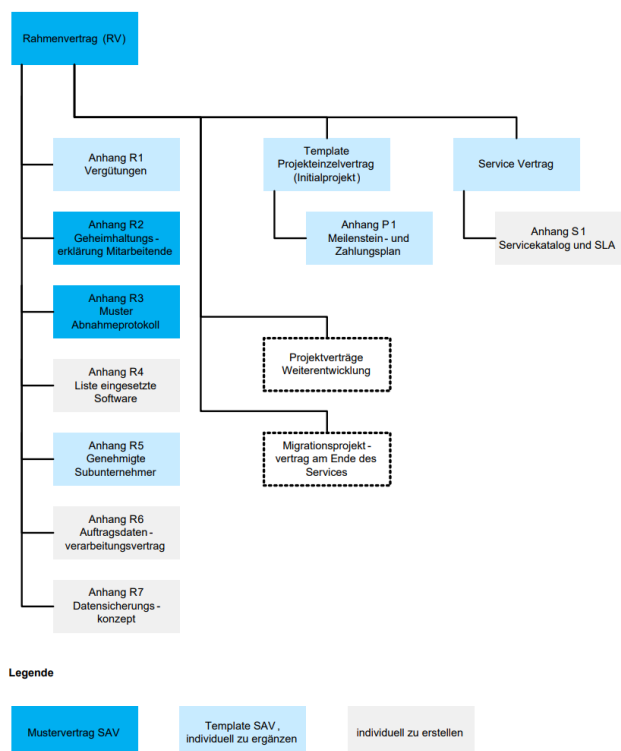
- Kosteneinsparung und klare Kostenstruktur
- Effizienzgewinn durch Know-how und Spezialisierung des Providers
- Straffung der eigenen Organisation und Fokus auf Kerngeschäft

Nachteile:

- Abhängigkeit vom Provider, besonders bei betriebskritischen Systemen/Prozessen
- Leistungsstörungen können gravierende Folgen für das Geschäft haben
- Teilweiser Kontrollverlust über Daten

Aufbau:

- Entweder ein bestimmter Vertrag für eine oder mehrere Dienstleistungen
- Oder Rahmenvertrag für eine Mehrzahl von Services mit grundlegenden Bestimmungen plus Einzelverträge für konkrete Services
- Ergänzung oft durch Service Level Agreements



SLA:

- Definiert Art, Quantität und Qualität der Outsourcing-Services
- Macht Leistungen messbar, z.B. Verfügbarkeit, Reaktionszeit oder Supportumfang
- Strategische und kommerzielle Kernpunkte gehören in den Hauptvertrag, nicht nur ins SLA

Phasen des Outsourcingvertrag: (sollte darüber Auskunft geben können)

- Auslagerung der IT-Infrastruktur
- Anschliessender Betrieb
- Rückübertragung

Beim Outsourcing-Vertrag ist die **Vertragsqualifikation** wichtig. Reines **Auftragsrecht** passt oft nicht, weil der Vertrag sonst jederzeit kündbar wäre. Meist überwiegen **werkvertragsähnliche Elemente**, da eine **konkret feststell- und messbare Leistungspflicht** geschuldet ist. Werden zusätzlich Systemkapazitäten bereitgestellt, kommen auch **mietvertragsähnliche Elemente** hinzu. Auftragsrechtliche Elemente gibt es eher bei Beratung oder nicht messbaren Tätigkeiten.

Beispiele zur vertragstypologischen Einordnung:

- **Entwicklung und Einführung** einer neuen IT-Systemumgebung: primär Werkvertragsrecht, evtl. auftragsrechtliche Elemente.
- **Übernahme** bestehender IT-Infrastruktur: kauf-, miet- und lizenzvertragliche Elemente beachten, je nach übertragener Komponente.
- **Auslagerung** von Personalressourcen: zusätzlich arbeitsrechtliche Bestimmungen relevant.
- **Betrieb** ausgelagerter Systeme/Anwendungen/Prozesse: meist werkvertraglicher Charakter, besonders bei Erfolgsgarantie oder SLAs.
- Reines **Bereithalten von Rechnerkapazität**: Nähe zu Miet- oder Pachtvertrag.
- Häufige Zusatzelemente:
 - Auftrag, z.B. Schulung oder Support
 - Hinterlegung, z.B. Datenauslagerung

Mängelrechte:

- Je nach Vertragselement gelten unterschiedliche Grundlagen:
 - **Kaufvertragliche Eigenschaften**: OR 97 ff. und Art. 197 ff. OR; Wandelung, Minderung oder Ersatzlieferung.
 - **Werkvertragliche Eigenschaften**: OR 97 ff. und Art. 363 ff. OR; Wandelung, Minderung oder Nachbesserung.
 - **Auftragsrechtliche Eigenschaften**: OR 97 ff. und Art. 394 ff. OR; vor allem Schadenersatz.

3.8.1. Regelungspunkte

- **Rahmenbedingungen**: Parteien, Provider-Informationen, Domizil und Auftraggeber klären.
- **Leistungsinhalt**: Kapazitäten, Verfügbarkeit, Antwort-/Reaktionszeiten und Support Levels genau definieren.
 - Messbar über SLAs/KPIs, z.B. Mindestverfügbarkeit, Bandbreite, Recovery Time/Point Objectives und Kundenzufriedenheit.
- **Vergütung**: Pauschalpreis, nutzungsabhängige Gebühren, Auslagen/Spesen, Rabatte und Anpassungsmöglichkeiten regeln.
- **Abrechnung/Zahlung**: Fälligkeit, Zahlungsmodalitäten, Verzug und Streit über Zahlungspflichten festlegen.
- **Informationssicherheit und Datenschutz**: Sicherheitsstandards, Personendaten, Zugriffe und Vertraulichkeit regeln.
- **Gewährleistung und Haftung**: Haftungsumfang, mittelbare Schäden und Ersatzmechanismen festlegen.
 - Möglich: **Konventionalstrafe** (Art. 160 OR) bei SLA-Verletzung oder **Bonus-Malus-Systeme** (Bei guter Leistung gibt es einen Bonus, bei schlechter Leistung einen Abzug bzw. eine Gutschrift für den Kunden.).
- **Vertragsdauer und Beendigung**: ordentliche/ausserordentliche Kündigung und Folgen der Auflösung, z.B. Backsourcing.
- **Weitere Bestimmungen**: anwendbares Recht, Gerichtsstand, Rechtsnachfolge, Formvorschriften und Unterschriften.

4. ZGB - Erklärungen

4.1. Anwendung des Rechts (Art. 1 ZGB)

1. Das Gesetz findet auf alle Rechtsfragen Anwendung, für die es nach Wortlaut oder Auslegung eine Bestimmung enthält.
2. Kann dem Gesetz keine Vorschrift entnommen werden, so soll das Gericht nach Gewohnheitsrecht und, wo auch ein solches fehlt, nach der Regel entscheiden, die es als Gesetzgeber aufstellen würde.
3. Es folgt dabei bewährter Lehre und Überlieferung.

4.2. Treu und Glauben (Art. 2 ZGB)

Art. 2 ZGB regelt, wie Rechte ausgeübt und Pflichten erfüllt werden müssen.

Grundsatz: Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.

Treu und Glauben ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Gemeint ist ein anständiges, redliches, aufrichtiges, zuverlässiges und rücksichtsvolles Verhalten im Rechtsverkehr.

Wichtige Funktionen:

- **Vertrauensschutz:** Wer berechtigtes Vertrauen in das Verhalten des Gegenübers gesetzt hat, soll nicht enttäuscht werden.
- **Verbot widersprüchlichen Verhaltens:** Wer sich zuerst auf eine bestimmte Weise verhält, darf später nicht treuwidrig das Gegenteil geltend machen.
- **Rechtsmissbrauchsverbot:** Der offenbare Missbrauch eines Rechts wird nicht geschützt.

Rechtsmissbrauch liegt nur bei krass stossendem Verhalten vor, z. B. bei Schikane, Schadenfreude oder Rache. Blosses formelles Bestehen auf einem Recht genügt nicht immer.

Beispiele:

- Ein Eigentümer lehnt zuerst alle vom Makler vermittelten Interessenten ab, schliesst später aber doch mit einem dieser Interessenten ab.
- Ein Aktionär stimmt einem Beschluss an der Generalversammlung zu und ficht denselben Beschluss später an.
- Ein Vermieter besteht auf einer Endreinigung, obwohl er weiss, dass das ganze Wohnhaus abgerissen wird.
- Ein Enterbter wartet trotz Hinweis auf seinen Pflichtteil zu lange und macht später rechtsmissbräuchlich Ansprüche geltend.

4.3. Guter Glaube (Art. 3 ZGB)

Der gute Glaube wird vermutet, wenn das Gesetz eine Rechtswirkung daran knüpft. Eine Person muss also ihren guten Glauben grundsätzlich nicht beweisen.

Guter Glaube bedeutet: Eine Person weiss trotz Rechtsmangel nicht, dass etwas rechtlich nicht in Ordnung ist. Gutgläubig ist, wer nicht bösgläubig ist.

Grenzen:

- Wer bei der erforderlichen Aufmerksamkeit nicht gutgläubig sein konnte, darf sich nicht auf den guten Glauben berufen.
- Es gibt keinen allgemeinen Gutglaubensschutz; Art. 3 ZGB gilt nur, wenn das Gesetz eine Rechtsfolge ausdrücklich vom guten Glauben abhängig macht.

- Für den Beweis der Bösgläubigkeit genügt, dass jemand aufgrund der Umstände nicht gutgläubig sein konnte.

Beispiele:

- Ein Autohändler genießt keinen Gutglaubensschutz, wenn er einen gestohlenen Ferrari kauft, ohne die Fahrzeugpapiere sorgfältig zu prüfen.
- Wer im Stadtpark von einem Fremden ein fabrikneues Handy zu einem Schleuderpreis kauft, kann sich kaum auf guten Glauben berufen.
- Wer eine bewegliche Sache in gutem Glauben zu Eigentum übertragen erhält, kann unter Umständen geschützt sein (vgl. Art. 933 ZGB).

4.4. Gerichtliches Ermessen (Art. 4 ZGB)

Wenn das Gesetz auf Ermessen, die Würdigung der Umstände oder wichtige Gründe verweist, entscheidet das Gericht nach Recht und Billigkeit.

Gerichtliches Ermessen gibt dem Gericht einen gewissen Spielraum, damit es im Einzelfall sachgerecht entscheiden kann. Es entscheidet aber nicht beliebig, sondern nach rechtlichen Grundsätzen. (Art. 336a Abs. 2 OR)

Beispiele:

- Fehlen Regeln zur Beteiligung eines Kommanditärs an Gewinn und Verlust, entscheidet das Gericht nach freiem Ermessen (Art. 601 Abs. 2 OR).
- Bei gewissen Folgen einer fristlosen Auflösung bestimmt das Gericht die vermögensrechtlichen Folgen unter Würdigung aller Umstände nach seinem Ermessen (Art. 337b Abs. 2 OR).

4.5. Beweisregel (Art. 8 ZGB)

Grundsatz: Wer aus einer behaupteten Tatsache Rechte ableitet, muss diese Tatsache beweisen, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt.

Im Zivilprozess gilt grundsätzlich die **Verhandlungsmaxime**: Die Parteien bringen Tatsachen und Beweise vor. Ist ein Sachverhalt bestritten, muss das Gericht durch Beweise überzeugt werden, z. B. durch Zeugen, Urkunden, Gutachten oder Augenschein.

=> Im Strafrecht sind **Untersuchungsmaxime** anwendbar

Beispiele:

- Der Käufer muss beweisen, dass er rechtzeitig eine Mängelrüge erhoben hat, wenn der Verkäufer dies bestreitet.
- Wer behauptet, einen Vermögenswert aus Eigengut gekauft zu haben, muss dies beweisen.

Wichtige Ausnahmen und Erleichterungen:

- **Beweislastumkehr**: Die Beweislast wird einer Partei zugeteilt, die sie normalerweise nicht tragen würde. (Art. 97 OR)
- **Beweisnot**: Eine Partei müsste etwas beweisen, kann dies aber faktisch oder rechtlich kaum. Gericht kann in solchen Fällen die Anforderung an den Beweis erleichtern. (z.B. Glaubhaftmachen genügt)
 - Patient kann nicht beweisen, dass Arzt während OP einen Kunstfehler gemacht hat, da er geistig nicht anwesend war
- **Beweiserleichterung**: Das Gericht senkt die Anforderungen an den Beweis; statt Vollbeweis genügt z. B. Glaubhaftmachen. Auch Beweislastumkehr kann hier geltend gemacht werden.

5. Arbeitsrecht

5.1. Nominatverträge

Gesetzlich geregelter Vertrag auf Arbeitsleistung

5.1.1. Arbeitsvertrag

Beim Arbeitsvertrag verpflichtet sich der Arbeitnehmer, gegen Bezahlung Arbeit für den Arbeitgeber zu leisten. Geschuldet ist kein bestimmter Erfolg, sondern ein sorgfältiges Tätigwerden.

Typische Merkmale:

- Subordination: Der Arbeitnehmer ordnet sich dem Arbeitgeber persönlich, betrieblich, zeitlich und teilweise wirtschaftlich unter
- Eingliederung in die Betriebsorganisation
- Weitere Hinweise auf ein Arbeitsverhältnis sind Sozialversicherungsbeiträge, Lohnfortzahlung bei Krankheit, fixe oder periodische Entschädigung, wirtschaftliche Abhängigkeit und ein Konkurrenzverbot

5.1.2. Werkvertrag

Beim Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer, gegen Bezahlung ein Werk für den Besteller herzustellen.

Typische Merkmale:

- Im Zentrum steht das Werk, zum Beispiel der Bau eines Hauses, ein Möbelstück nach Wunsch, ein Bauplan, ein Massanzug oder ein Haarschnitt
- Geschuldet ist der Erfolg
- Der Unternehmer verwendet meist eigene Arbeitsmittel
- Einmalig

5.1.3. Auftrag

Beim Auftrag übernimmt der Beauftragte die Pflicht, im Interesse des Auftraggebers bestimmte Geschäfte oder Dienste zu besorgen.

Typische Merkmale:

- Im Zentrum steht das sorgfältige Tätigwerden
- Der Erfolg ist nicht geschuldet
- Der Beauftragte hat eine **Treuepflicht**
- Es besteht ein besonderes Vertrauensverhältnis
- Der Beauftragte handelt in selbständiger Stellung

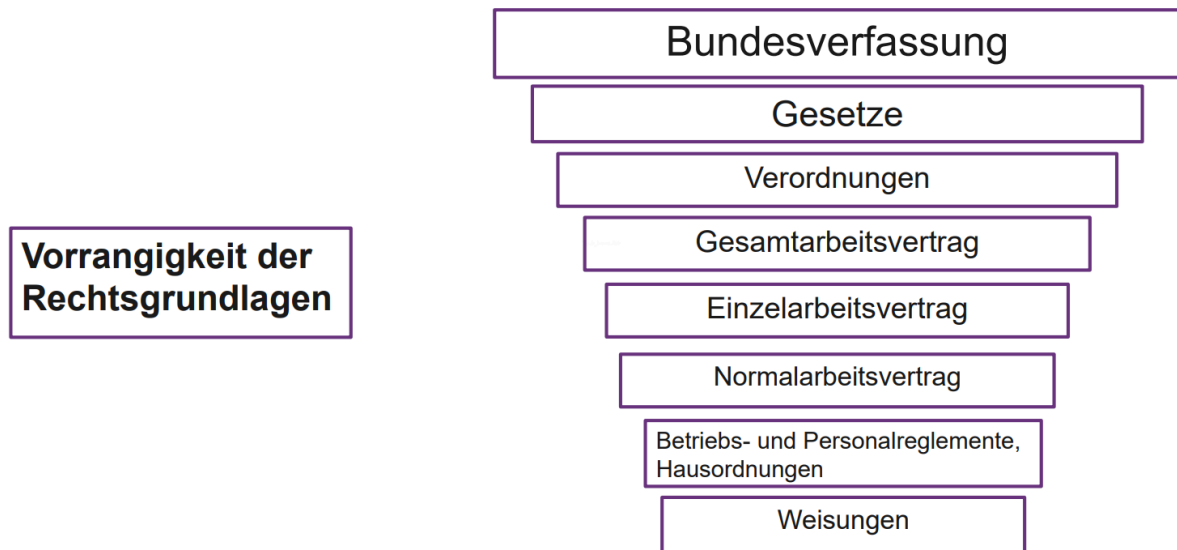
5.1.4. Abgrenzung

Werkvertrag = Erfolg geschuldet

Arbeitsvertrag = Sorgfältiges Tätigwerden und Subordination/Eingliederung in Betrieb

Auftrag = Sorgfältiges Tätigwerden

5.2. Rechtsgrundlagen zum Arbeitsrecht



5.3. Entstehung eines Arbeitsverhältnisses

5.3.1. Einzelarbeitsvertrag (EAV)

Der EAV nach Art. 319 ff. OR ist grundsätzlich formfrei und kann schriftlich, mündlich oder durch **Konkludentes Verhalten**: schlüssiges Verhalten ohne ausdrückliche Erklärung entstehen (Art. 320 OR). Schriftform braucht es für Sonderabreden wie Verlängerung der Probezeit, Lohnverzicht bei Überstunden oder Konkurrenzverbot. Zu beachten sind relativ zwingende (Art. 362 OR) und absolut zwingende Bestimmungen (Art. 361 OR) zum Schutz des Arbeitnehmers.

Voraussetzungen:

- Übereinstimmende gegenseitige Willenserklärung (Art. 1 OR)
- Einigung über die Hauptpunkte: Parteien, Beginn und Dauer, Umfang, Arbeitsort, Lohn, Arbeitszeit, Ferien, Probezeit und Kündigungsfrist
- Handlungsfähigkeit der Parteien: Urteilsfähigkeit und Mündigkeit
- Kein nichtiger Vertragsinhalt: nicht sittenwidrig, widerrechtlich oder unmöglich

5.3.2. Besondere Einzelarbeitsverträge

Besondere EAV unterliegen einfacher Schriftlichkeit oder besonderen Bestimmungen:

- Lehrvertrag (Art. 344a Abs. 1 OR)
- Handelsreisendenvertrag (Art. 347a Abs. 1 OR)
- Heimarbeitsvertrag: schriftliche Mitteilung der Arbeitsbedingungen (Art. 351a Abs. 1 OR)

5.3.3. Gesamtarbeitsvertrag (GAV)

Benötigt einfache Schriftlichkeit (Art. 356c Abs. 1 OR).

5.3.4. Normalarbeitsvertrag (NAV)

Der NAV ist ein behördlicher Erlass mit arbeitsvertraglichen Bestimmungen, die zwingend oder empfehlend sein können. Es gibt NAV mit zwingenden Mindestlöhnen und NAV mit Bestimmungen über das Arbeitsverhältnis. Beispiel: NAV Hauswirtschaft vom 20. Oktober 2010 mit Mindestlohn für Hausangestellte in Privathaushalten.

5.4. Aufbau Arbeitsvertrag

Titelblatt:

- Bezeichnung, Parteien, Präambel

Hauptteil:

- Umschreibung des Tätigkeitsbereichs. Dieser Umschreibung kann v. a. Bedeutung zukommen, wenn es um die Frage geht, welche Arbeiten zumutbar sind
- Einordnung im Betrieb (wichtig für die Abgrenzung zum Auftrag: Nennung von Funktion, Vorgesetztem, Arbeitsort)
- Beginn und Dauer des Arbeitsverhältnisses
- Probezeit
- Beendigung des Vertrags
- Arbeitszeit
- Überstunden
- Lohn / Spesen / 13. Monatslohn / Bonus
- Ferien, Feiertage und Freizeit
- Absenzen des Arbeitnehmers (Krankheit, Unfall, Schwangerschaft, Militärdienst etc.)
- Berufliche Vorsorge

Schlussbestimmungen

5.5. Pflichten des Arbeitnehmers

5.5.1. Persönliche Arbeitspflicht (Art. 321 OR)

- Arbeit ist persönlich zu leisten
- Ausnahme: anders vereinbart oder aus Umständen ersichtlich
- Übertragung an Dritte nur zulässig, wenn üblich oder vereinbart

5.5.2. Befolgung von Anordnungen und Weisungen (Art. 321d OR)

- Arbeitgeber darf allgemeine Anordnungen und besondere Weisungen erlassen
- Betrifft Ausführung der Arbeit und Verhalten im Betrieb oder Haushalt
- Arbeitnehmer muss Weisungen nach Treu und Glauben befolgen
- Grenzen: Vertrag, Persönlichkeitsschutz und Treu und Glauben
- Unzulässig: willkürliche oder schikanöse Weisungen

5.5.3. Sorgfalts- und Treuepflicht (Art. 321a OR)

- Arbeit sorgfältig ausführen
- Nach Treu und Glauben im Interesse des Arbeitgebers handeln
- Arbeitsmittel, Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge fachgerecht behandeln
- Keine konkurrenzierenden oder treuwidrigen Tätigkeiten während des Arbeitsverhältnisses
- Beispiele: Konkurrenzierung, Herabsetzung der Leistungsfähigkeit, Schädigung des Ansehens des Arbeitgebers

5.5.4. Geheimhaltung von Fabrikations- und Geschäftsgeheimnissen (Art. 321a Abs. 4 OR)

- Geheimhaltungspflicht für Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse
- Gilt unter Umständen auch nach Ende des Arbeitsverhältnisses abgeschwächt weiter
- Geheim ist eine Tatsache, wenn sie nicht offenkundig oder allgemein zugänglich ist
- Arbeitgeber muss ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse haben und Geheimhaltung wollen
- Geheimnis braucht Bezug zum Unternehmen, z.B. Fabrikation oder Geschäft
- Beispiele: Kundenkarteien, Herstellungsverfahren, Algorithmen, spezielles Know-how
- Information muss das Geschäftsergebnis beeinflussen können

- Zur Rechtssicherheit Geschäftsgeheimnisse ausdrücklich kennzeichnen und identifizierbar machen
- Strafrechtlicher Schutz: Art. 162 StGB

5.5.5. Haftung des Arbeitnehmers aus Vertragsverletzung (Art. 321e OR)

- Arbeitnehmer haftet für Schaden, den er dem Arbeitgeber absichtlich oder fahrlässig zufügt
- Haftung beurteilt sich nach dem konkreten Einzelfall und dem geschuldeten Sorgfaltsmass

Voraussetzungen:

- Schaden: vom Arbeitgeber zu beweisen
- Vertragsverletzung, z.B. Arbeits-, Sorgfalts- oder Treuepflichtverletzung: vom Arbeitgeber zu beweisen
- Adäquater Kausalzusammenhang zwischen Schaden und Vertragsverletzung: vom Arbeitgeber zu beweisen
- Verschulden des Arbeitnehmers: wird vermutet, **Exkulpation**: Entlastungsbeweis, dass ihn kein Verschulden trifft

Kriterien für das Haftungsmass:

- Konkretes Arbeitsverhältnis und Berufsrisiko
- Bildungsgrad, Fachkenntnisse und Lohnhöhe
- Fähigkeiten und Eigenschaften des Arbeitnehmers, die der Arbeitgeber kannte oder kennen musste
- Mitverschulden, Einwilligung oder Anordnung des Arbeitgebers

5.5.6. Überstundenarbeit (Art. 321c OR)

- Überschreitung der vertraglich vereinbarten, üblichen oder durch NAV/GAV bestimmten Arbeitszeit
- Arbeitnehmer muss Überstunden leisten, wenn sie notwendig, zumutbar und nach Treu und Glauben leistbar sind
- Arbeitgeber muss Überstunden nicht ausdrücklich anordnen, Pflicht kann sich aus berechtigten Interessen des Arbeitgebers ergeben
- Ausgleich mit Freizeit gleicher Dauer möglich, wenn Arbeitnehmer einverstanden ist
- Ohne Freizeitausgleich: Lohn plus Zuschlag von mindestens 25%, sofern nichts anderes schriftlich, durch NAV oder GAV bestimmt ist

5.5.7. Abgrenzung Überstunden / Überzeit

- **Überstunden** betreffen die Überschreitung der vertraglichen oder üblichen Arbeitszeit (BGE 116 II 70)
- **Überzeit** beginnt bei Überschreitung der gesetzlichen Höchstarbeitszeit nach ArG
- Abweichende Vereinbarungen zu Überstundenvergütung werden durch das ArG begrenzt
- Leitende Arbeitnehmer sind dem Arbeitsgesetz nicht unterstellt (Art. 3 lit. d ArG)

5.6. Konkurrenzverbot (Art. 340 ff. OR)

- Vertragsklausel: Arbeitnehmer darf Arbeitgeberin nach Ende des Arbeitsverhältnisses nicht konkurrenzieren
- Gilt für Tätigkeit bei Dritten oder selbständige konkurrenzierende Tätigkeit

Voraussetzungen für Gültigkeit:

- Handlungsfähigkeit des Arbeitnehmers
- Schriftliche Vereinbarung mit Unterschrift des Arbeitnehmers
- Konkurrenzierende Tätigkeit, also gleichartige Leistungen
- Einblick in Kundenkreis oder Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse
- Erhebliches Schädigungspotenzial für die Arbeitgeberin
- Angemessene Begrenzung nach Ort, Zeit und Gegenstand; i.d.R. höchstens drei Jahre

Konventionalstrafe:

- Kann gleichzeitig vereinbart werden
- Bei Übermässigkeit kann der Richter sie herabsetzen (Art. 163 Abs. 3 OR)

5.7. Pflichten des Arbeitgebers

5.7.1. Lohn (Art. 322 ff. OR)

- Arbeitgeber schuldet den vereinbarten, üblichen oder durch NAV/GAV bestimmten Lohn
- Auszahlung grundsätzlich Ende jedes Monats, sofern nichts anderes vereinbart, üblich oder durch NAV/GAV bestimmt ist (Art. 323 OR)

Lohnarten:

- Stundenlohn, Fixlohn, Akkordlohn
- Anteil am Geschäftsergebnis oder individuelle Erfolgsbeteiligung
- Provision (Art. 322b OR)
- Gratifikation als Sondervergütung bei besonderen Anlässen (Art. 322d OR)
- Naturallohn, z.B. Kost und Logis
- Lohnzulagen, z.B. Überstunden-, Nacht-, Sonntags-, Schicht-, Feiertags- und Ferienvergütung
- Fringe Benefits, z.B. Vergünstigungen, Repräsentationsspesen, Clubmitgliedschaften

5.7.2. Lohn bei Verhinderung der Arbeitsleistung (Art. 324 ff. OR)

- Arbeitnehmer ist arbeitsbereit, kann aber wegen des Arbeitgebers nicht arbeiten
- Beispiel: Arbeitgeber nimmt die angebotene Arbeit nicht (z.B. Zutrittsverweigerung) an oder stellt nötige Arbeitsmittel/Schutzmassnahmen nicht bereit
- Folge: Lohn bleibt geschuldet, obwohl keine Arbeit geleistet wird
- Arbeitnehmer muss die ausgefallene Arbeit nicht nachholen
- Kein Anspruch bei objektiven Gründen ausserhalb des Betriebsrisikos, z.B. Krieg, Einfuhrverbote oder unzumutbare rechtliche Risiken

5.7.3. Lohnfortzahlung bei Verhinderung des Arbeitnehmers (Art. 324a OR)

Gründe die in seiner Person liegen:

- z.B. Krankheit, Unfall, Schwangerschaft, Militärdienst, Zivildienst, Arztbesuch, Umzug, Heirat oder Pflege Angehöriger

Verschuldensart:

- Ohne Verschulden: Unfälle
- Mit Verschulden: Waghalsige Unternehmen

Lohnfortzahlungspflicht besteht nur bei ohne Verschulden

Keine Lohnfortzahlung bei externen Hindernissen wie Naturkatastrophen, Verkehrsproblemen, Flugverbot, Schneefall oder Pandemie

Dauer des Arbeitsverhältnisses:

- Befristetes Arbeitsverhältnis: Anspruch nur, wenn für länger als drei Monate eingegangen
- Unbefristetes Arbeitsverhältnis: Anspruch erst nach drei Monaten Dauer

Dauer der Lohnfortzahlung:

- Im ersten Dienstjahr drei Wochen
- Danach angemessene Zeit nach Berner-, Basler- oder Zürcher Skala
- Gleichwertige vertragliche Lösung möglich, z.B. Taggeld mindestens 80% des Lohns während mindestens 720 von 900 Tagen, bei mindestens hälftiger Prämienteilung und max. 3 Karenztagen
- Anspruch entsteht jedes Dienstjahr neu und gilt insgesamt, nicht pro Krankheitsereignis
- Bei teilweiser Verhinderung verlängert sich der Anspruch bis zur vollen Lohnfortzahlung

Berner Skala:

- 1. Dienstjahr ab 4. Arbeitsmonat: 3 Wochen
- 2. Dienstjahr: 1 Monat
- 3. und 4. Dienstjahr: 2 Monate
- 5. bis 9. Dienstjahr: 3 Monate
- 10. bis 14. Dienstjahr: 4 Monate

5.7.4. Schutz der Persönlichkeit des Arbeitnehmers (Art. 328 OR)

- Arbeitgeber muss Persönlichkeit des Arbeitnehmers achten und schützen
- Besondere Rücksicht auf Gesundheit und Sittlichkeit
- Schutz vor sexueller Belästigung
- Opfer sexueller Belästigung dürfen keine weiteren Nachteile erleiden
- Arbeitgeber muss Massnahmen zum Schutz von Leben, Gesundheit und persönlicher Integrität treffen
- Massnahmen müssen notwendig, technisch möglich, betrieblich angemessen und zumutbar sein
- Konkretisierung vor allem im Arbeitsgesetz und den dazugehörigen Verordnungen

5.7.5. Erstellen eines Arbeitszeugnisses(Art. 330a OR)

Ein Arbeitnehmer kann jederzeit ein Zeugnis verlangen, das sich über die Art und die Dauer des Arbeitsverhältnisses sowie über seine Leistungen und sein Verhalten ausspricht

Soll enthalten:

- Identität des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers
- Beginn und Ende des Arbeitsverhältnisses
- Detaillierte Auflistung der wichtigen Funktionen und der das Arbeitsverhältnis prägenden Tätigkeiten des Arbeitnehmers und deren Zeitdauer
- Aussagekräftige Bewertung der Leistung (Arbeitsqualität und -quantität) des Arbeitnehmers und seines Verhaltens
- Rechtsgültige Unterschrift des Arbeitgebers

5.7.5.1. Form des Arbeitszeugnisses

Formelle Anforderungen:

- Maschinenschrift (Computer)
- Sprachliche Korrektheit (klar, verständlich, Rechtschreibung)
- Ordentlicher Eindruck

Materielle Anforderungen:

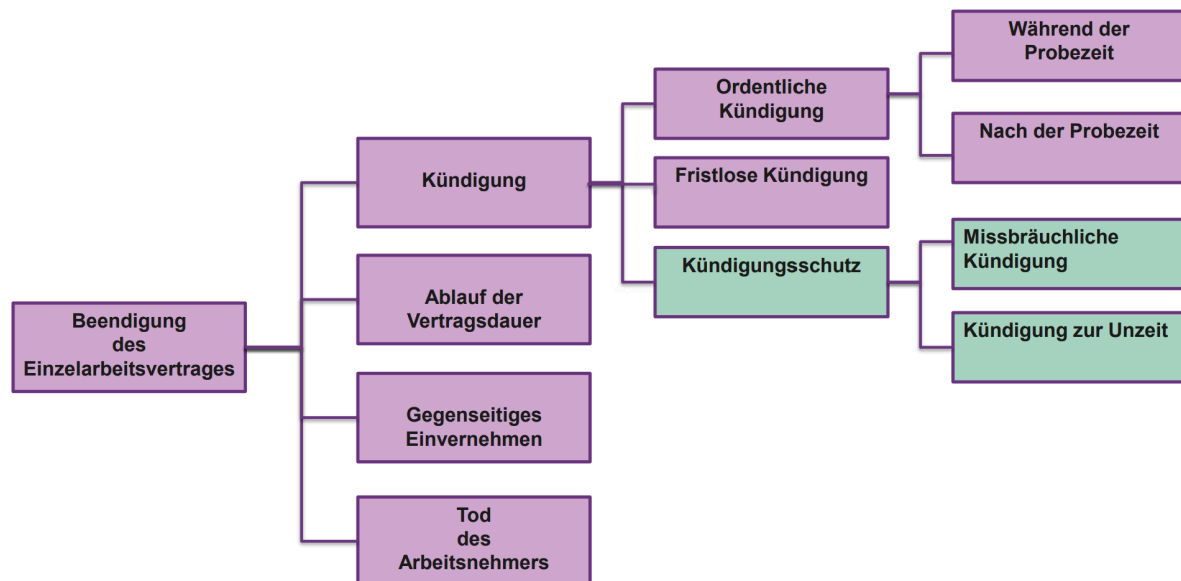
- Werturteilen (übliche Massstäbe)
- Vollständigkeit
- Wahrheitsgetreue Aussagen
- Aussagen die nicht in Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis stehen sind unzulässig
- Wohlwollende Formulierung
 - Jedoch: Negative Tatsachen dürfen/müssen im Zeugnis erwähnt werden, sofern sie für die Gesamtbeurteilung des Arbeitnehmers erheblich sind
- Unzulässigkeit zweideutiger Formulierungen (Klarheit)
 - z.B «er war stets bemüht»

5.8. Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Möglichkeiten beim Einzelarbeitsvertrag:

- Kündigung des unbefristeten Einzelarbeitsvertrags (Art. 335 ff. OR)
- Zeitablauf beim befristeten Einzelarbeitsvertrag (Art. 334 OR)
- Aufhebungsvertrag (Art. 115 OR)

- Fristlose Kündigung (Art. 337 ff. OR)
- Tod des Arbeitnehmers (Art. 338 OR)
- Beachte: Nicht der Konkurs des Arbeitgebers



5.9. Die Kündigung (Art. 335c OR)

- In der Schweiz gilt bei privatrechtlichen Arbeitsverhältnissen Kündigungsfreiheit
- Kündigung ist ohne besonderen Grund möglich, wenn vertragliche oder gesetzliche Fristen eingehalten werden
- Kündigung ist eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung
- Entscheidend ist Erhalt bei der Gegenpartei, nicht nur Versand
- Bei Endtermin, z.B. Monatsende, muss die Kündigung spätestens am letzten Tag des Monats bekannt sein
- Kündigung ist formfrei, sofern der Arbeitsvertrag nichts anderes vorsieht
- Auf Verlangen der anderen Partei muss die Kündigung schriftlich begründet werden (Art. 335 Abs. 2 OR)

Kündigungsfristen (insofern nicht anders vereinbart):

- 1. Dienstjahr: 1 Monat
- 2. > 9. Dienstjahr: 2 Monate
- Ab dem 10. Dienstjahr: 3 Monate

Kündigungsfrist darf nicht unter einem Monat sein, ausser es ist im GAV anders definiert.

5.9.1. Kündigung während der Probezeit (Art. 335b OR)

- Erster Monat gilt als Probezeit (bei unbefristet)
 - Kann abweichen und kleiner oder länger festgelegt werden (max. 3 Monate)
 - Bei befristeten Arbeitsverhältnissen gibt es grundsätzlich keine Probezeit
- Kündigungsfrist von 7 Kalendertagen in der Probezeit. Kann anders definiert werden.
- Keinen Kündigungsschutz während Probezeit (beidseitig)
- Verlängerung nur unter Bedingungen (z.B. Unfall, Krankheit)

Anschauungsbeispiel: Roland befindet sich noch in der Probezeit. Diese beträgt drei Monate. Wann muss der Arbeitgeber Roland spätestens kündigen, wenn er die Kündigung noch in der Probezeit aussprechen möchte? Wann endet demnach das Arbeitsverhältnis?



5.9.2. Kündigungsschutz

- Sachlicher Kündigungsschutz (missbräuchliche Kündigung, Art 336 ff. OR)
 - Gilt auch während Probezeit
- Zeitlicher Kündigungsschutz (Kündigung zur Unzeit, Art. 336c ff. OR)
 - Gilt erst nach Ablauf der Probezeit

5.9.3. Missbräuchliche Kündigung

- Kündigungsfreiheit gilt, aber Beweggründe dürfen nicht missbräuchlich sein
- Art. 336 OR nennt Beispiele, aber nicht abschliessend
- Missbräuchlich ist z.B. Kündigung ohne zureichenden Grund kurz vor Pensionsanspruch nach langer Dienstzeit (44 Jahre)
- Rachekündigung: Kündigung, weil Arbeitnehmer berechnete Ansprüche oder Rechte geltend macht
- Vereitelungskündigung: Kündigung, um Ansprüche der anderen Partei zu verhindern, z.B. Bonus oder Dienstaltersgeschenk
- Kündigung trotz ungenügender Schutzmassnahmen des Arbeitgebers, z.B. bei gesundheitlicher Belastung
- Ausübung verfassungsmässiger Rechte ist grundsätzlich kein Kündigungsgrund, solange keine Treupflicht verletzt wird

Fristen:

- Einsprachefrist (bis zum Ablauf der Kündigungsfrist)
- Klagefrist (180n Tage nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses)

Merke: Bei der Klagefrist handelt es sich um eine **Verwirkungsfrist**: Frist, nach deren Ablauf ein Anspruch endgültig nicht mehr durchgesetzt werden kann, d.h. der Richter beachtet diese von Amtes wegen.

Rechtsfolgen:

- Selbst wenn das Gericht eine Kündigung als missbräuchlich qualifiziert, ist diese rechtswirksam
- Anspruch auf Entschädigungszahlung von max. sechs Monatslöhnen (ermessen des Richters)
- Schwere des Eingriffs in die Persönlichkeit, Grad der Missbräuchlichkeit und Verletzung des Vertrauensverhältnisses spielen eine Rolle (e.g. dauer und enge des Arbeitsbeziehung)
- In Praxis sind hohe Entschädigungen selten

Mögliche Formulierung einer Einsprache: *Sie haben mir das Arbeitsverhältnis am (Datum) auf den (Kündigungstermin) gekündigt. Ich betrachte diese Kündigung als missbräuchlich und erhebe dagegen Einsprache. Ich bin bereit, das Arbeitsverhältnis fortzusetzen. Ich ersuche Sie, mir innert fünf Tagen schriftlich mitzuteilen, ob Sie mit einer Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses einverstanden sind oder ob Sie an der Kündigung festhalten wollen. Wenn Sie an der Kündigung festhalten, ersuche ich Sie, mir ebenfalls innert fünf Tagen die Kündigungsgründe schriftlich bekannt zu geben. Ich behalte mir vor, diese Kündigung als missbräuchlich anzufechten und vor Gericht eine Entschädigung geltend zu machen.*

5.9.4. Zeitlicher Kündigungsschutz (Art. 336c OR)

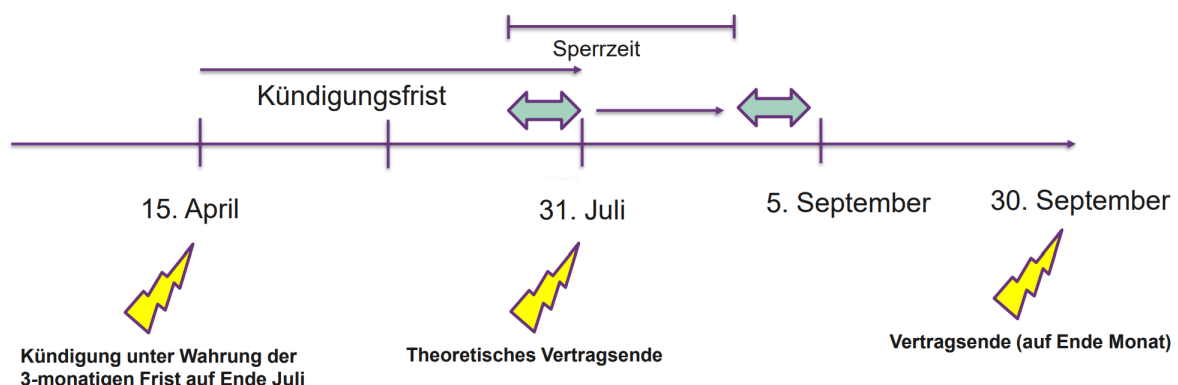
- Grundsatz: Kündigung ist frei möglich, aber Art. 336c OR schützt zeitlich begrenzt
- Schutzgründe: Krankheit, Unfall, Schwangerschaft, Mutterschaft und Dienstleistung für Hilfsaktionen im Ausland
- Gilt auch bei Teilzeit, Temporärarbeit und grundsätzlich bei Freistellung
- Keine Anwendung bei befristeten Arbeitsverhältnissen, Aufhebungsverträgen und gerechtfertigter fristloser Entlassung
- Sperrfrist gilt erst nach Ablauf der Probezeit
- Schutz gilt nur bei Arbeitgeberkündigung

5.9.4.1. Sperrfristen

Kündigung während der Sperrzeit ist nichtig.

- Militär: 4 Wochen vor und nach dem Dienst (muss mehr als 11 Tage dauern)
- Krankheit und Unfall:
 - 30 Tage im 1. Dienstjahr
 - 90 Tage im 2.-5. Dienstjahr
 - 180 Tage ab 6. Dienstjahr
- Schwangerschaft: Ganze Schwangerschaft + 16 Wochen danach
- Hilfsaktionen im Ausland

Merke: Die Anwendung der Sperrfristen hat mit der Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers bei Arbeitsverhinderung nichts zu tun.



5.10. Ausserordentliche Kündigung / Fristlose Kündigung (Art. 337 OR)

- Arbeitgeber und Arbeitnehmer können bei wichtigen Gründen jederzeit fristlos kündigen
- Auf Verlangen der anderen Partei muss die Kündigung schriftlich begründet werden

- Wichtiger Grund: Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses ist nach Treu und Glauben nicht mehr zumutbar (Vertrauensverhältnis zerstört)
- Gericht entscheidet nach Ermessen, ob ein wichtiger Grund vorliegt
- Unverschuldete Arbeitsverhinderung des Arbeitnehmers gilt nie als wichtiger Grund

Mögliche Gründe (Arbeitgeber):

- Wegen Veruntreuung am Arbeitsplatz wird ein Buchhalter fristlos entlassen.
- Annahme von Schmiergeldern
- Unwahre Angaben bei der Anstellung
- Eigenmächtiger Ferienbezug
- Verrat von Geschäftsgeheimnissen
- Grobe Missachtung von Weisung
- Weniger schwerwiegende Verfehlungen, aber nach erfolgter Abmahnung (heikel):
 - Übermässiges privates Telefonieren
 - Ungepflegtes Erscheinen in repräsentativen Berufen
 - Grössere Verspätungen
 - Verstoss gegen Weisungen (beharrliche oder wiederholte Nichtbeachten von berechtigten Weisungen)

Merke: Die fristlose Auflösung ist ein Notventil und wird daher in der Gerichtspraxis nur dann geschützt, wenn der Anlass zur Kündigung ausreichend gravierend ist.

Mögliche Gründe (Arbeitnehmer):

- Beschimpfungen und Tätlichkeiten durch den Arbeitgeber
- Unsittliche Anträge oder Belästigungen durch den Arbeitgeber
- Kränkungen und Belästigungen durch Mitarbeiter ohne Eingreifen des Arbeitgebers
- Weisungen, sittenwidrige oder strafbare Handlungen zu begehen
- nicht behobene Sicherheitsmängel, mangelnde Sicherheitsvorrichtungen
- unzumutbares Arbeitsklima ohne Eingreifen des Arbeitgebers
- zu weit gehende Überwachungen am Arbeitsplatz oder im Privatbereich
- schwerwiegende grundlose Verdächtigungen oder üble Nachreden durch den Arbeitgeber
- Der einzige vom Gesetz konkret genannte Grund ist derjenige der Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit) des Arbeitgebers (Art. 337a OR). Vereinzelt verspätet erfolgte Lohnauszahlungen stellen hingegen keinen wichtigen Grund für eine fristlose Kündigung dar.

Merke: Der Grund muss auch hier gravierend sein. Bei geringeren Problemen hat auch der Arbeitnehmer zuerst eine Verwarnung auszusprechen.

Folgen:

- Schadensersatz muss geleistet werden
- Ansonsten nach richterlichen Ermessen

Folgen bei ungerechtfertigter fristloser Kündigung (Art. 337c OR):

- Lohnersatz bis zum ordentlichen Vertragsende
- Anrechnung von Ersparnissen und anderweitigem Verdienst
- Zusätzliche Entschädigung nach Ermessen des Richters, max. 6 Monatslöhne

5.11. Rechte an Erfindung und Designs (Art. 332 OR)

- Erfindungen/Designs aus dienstlicher Tätigkeit und Vertragspflicht gehören dem Arbeitgeber
- Andere dienstliche Erfindungen/Designs kann sich der Arbeitgeber nur durch schriftliche Abrede sichern

- Arbeitnehmer muss solche Erfindungen/Designs schriftlich melden
- Arbeitgeber muss innert 6 Monaten schriftlich erklären, ob er sie erwerben oder freigeben will
- Bei Erwerb schuldet der Arbeitgeber eine besondere angemessene Vergütung
- Höhe richtet sich u.a. nach wirtschaftlichem Wert, Mitwirkung des Arbeitgebers, Aufwand des Arbeitnehmers und Stellung im Betrieb

6. Werkvertrag (Art. 363 OR)

- Kann formfrei geschlossen werden
- Gegenstand eines Werkvertrages kann die Erstellung aber auch die Veränderung (z.B. Reparatur, Bearbeitung, Veredelung) einer Sache sein.
 - Bspw.: Tuning, Herstellung eines Eherings, Haarschnitt, Hausbau, Anfertigen eines Möbelstücks, Bauplan des Ingenieurs, Anzug nach Mass, Autoreparatur, Aufbau einer umfassenden und «massgeschneiderten» IT- Landschaft

6.1. Höhe der Vergütung

Fixpreis nach Art. 373 Abs. 1 OR:

Bei einem **fest vereinbarten Werklohn** bleibt der Preis grundsätzlich gleich, auch wenn der Aufwand höher oder tiefer ist. Nur bei **ausserordentlichen, unvorhersehbaren** Umständen kann das Gericht den Preis erhöhen oder den Vertrag auflösen, z.B. bei Naturereignissen, behördlichen Massnahmen oder Pflichtverletzungen des Bestellers. Grundlage: Art. 373 Abs. 2 OR.

6.1.1. Keine oder nur ungefähre Preisvereinbarung (Art. 374 OR)

- Fehlt eine klare Preisvereinbarung, wird der Werklohn nach dem Wert der Arbeit und den Aufwendungen des Unternehmers bestimmt.
- Wird ein ungefähre **Kostenansatz** ohne Zutun des Bestellers unverhältnismässig überschritten, kann der Besteller nach Art. 375 OR vom Vertrag zurücktreten.
 - Faustregel: Überschreitung von ca. 10%.
- Bei Bauten auf eigenem Grundstück kann der Besteller zusätzlich eine Herabsetzung verlangen oder die Fortführung entziehen.

6.1.2. Vergütung nach der SIA - Norm 118

- Enthält Regeln betreffend Abschluss, Inhalt und Abwicklung von Verträgen über Bauarbeiten.
- Ist nur anwendbar, wenn die Vertragsparteien ihre Übernahme ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart haben.

Vergütung nach SIA-Norm:

- Einheitspreis
- Globalpreis
- Pauschalpreis
- Regiepreis

6.2. Mangelhaftung (Art. 367ff. OR)

- Unternehmer muss verschuldensunabhängig für **Werkmangel** einstehen (Art. 368 OR)
- Ausübung der Mängelrechte ist an folgende Voraussetzungen geknüpft:
 - Werk ist bei Ablieferung mangelhaft
 - Besteller erfüllt **Prüf- und Rügeobliegenheit**
 - Bei ausdrücklicher oder stillschweigender Genehmigung verliert er die Mängelrechte.
 - **Stillschweigende Genehmigung**: keine rechtzeitige Prüfung oder Rüge.
 - Rüge so bald wie möglich; bei versteckten Mängeln sofort nach Entdeckung.
 - Grundlage: Art. 367 und 370 OR.
 - Keine Ausschlussgründe:
 - Mangel stammt nicht vom Stoff/Baugrund des Bestellers, sonst haftet der Unternehmer nur bei verletzter **Anzeigepflicht**.
 - Keine unsachgemässe Weisung des Bestellers, sonst Ausschluss nur, wenn der Unternehmer rechtzeitig gewarnt hat (Art. 369 OR).

- **Gewährleistung** wurde nicht gültig wegbedungen (Schranken: Art. 100 und 199 OR).
- ▶ Anspruch ist nicht verjährt (Art. 371 OR):
 - Bewegliches Werk: 2 Jahre ab Abnahme.
 - Bewegliches Werk, das bestimmungsgemäss in unbewegliches Werk integriert wird und dessen Mangelhaftigkeit verursacht: 5 Jahre.
 - Unbewegliches Werk: 5 Jahre ab Abnahme, gilt auch gegenüber Architekt/Ingenieur.
 - Im Übrigen gelten die kaufrechtlichen Verjährungsregeln sinngemäss.

6.2.1. Seit Januar 2026

Betrifft: Art. 368 OR, Art. 367 OR, Art. 219a OR, Art. 371 OR

- Stärkere Stellung von Bauherren und Immobilienkäufern bei Baumängeln.
- Rügefrist für offene und versteckte Mängel: 60 Tage ab Ablieferung bzw. Entdeckung.
 - ▶ Vertragliche Verkürzung nicht zulässig.
- Nachbesserungsrecht bei Baumängeln kann vertraglich nicht mehr ausgeschlossen werden.
 - ▶ Gilt für Bauwerkverträge sowie für Grundstücke mit Neubauten, die noch erstellt werden oder höchstens zwei Jahre alt sind.

II. Mängelrüge, unentgeltliche Verbesserung und Verjährung	Art. 219⁸⁸ Kaufvertrag ¹ Die Frist für die Mängelrüge beträgt beim Grundstückskauf 60 Tage. Mängel, die bei der übungsgemässen Untersuchung nicht erkennbar waren, sind innert 60 Tagen nach ihrer Entdeckung anzuzeigen. Die Vereinbarung kürzerer Fristen ist unwirksam. ² Der Käufer eines Grundstücks mit einer Baute, die noch zu errichten ist oder weniger als zwei Jahre vor dem Verkauf neu errichtet wurde, kann auch unentgeltliche Verbesserung verlangen. Dieser Anspruch untersteht den Bestimmungen über den Werkvertrag. ³ Die Ansprüche des Käufers wegen Mängeln des Grundstücks verjähren mit Ablauf von fünf Jahren nach dem Erwerb des Eigentums. Die Verjährungsfrist kann nicht zu Lasten des Käufers abgeändert werden.	b. Recht des Bestellers bei Mängeln	Art. 368 ¹ Leidet das Werk an so erheblichen Mängeln oder weicht es sonst so sehr vom Verträge ab, dass es für den Besteller unbrauchbar ist oder dass ihm die Annahme billigerweise nicht zugemutet werden kann, so darf er diese verweigern und bei Verschulden des Unternehmers Schadenersatz fordern.
4. Haftung für Mängel a. Feststellung der Mängel	Art. 367 ¹ Nach Ablieferung des Werkes hat der Besteller, sobald es nach dem üblichen Geschäftsgange tunlich ist, dessen Beschaffenheit zu prüfen und den Unternehmer von allfälligen Mängeln in Kenntnis zu setzen. ^{1bis} Die Frist für die Mängelrüge beträgt bei einem unbeweglichen Werk 60 Tage. Die Vereinbarung einer kürzeren Frist ist unwirksam. Dasselbe gilt für die folgenden Mängel eines Werks, die die Mangelhaftigkeit eines unbeweglichen Werks verursacht haben: a. Mängel eines beweglichen Werks, das bestimmungsgemäss in das unbewegliche Werk integriert worden ist; b. Mängel eines Werks, das von einem Architekten oder Ingenieur erstellt und bestimmungsgemäss als Grundlage für die Erstellung des unbeweglichen Werks verwendet worden ist.²⁵⁶ ² Jeder Teil ist berechtigt, auf seine Kosten eine Prüfung des Werkes durch Sachverständige und die Beurkundung des Befundes zu verlangen.		² Sind die Mängel oder die Abweichungen vom Verträge minder erheblich, so kann der Besteller einen dem Minderwerte des Werkes entsprechenden Abzug am Lohne machen oder auch, sofern dieses dem Unternehmer nicht übermässige Kosten verursacht, die unentgeltliche Verbesserung des Werkes und bei Verschulden Schadenersatz verlangen. Im Falle der unentgeltlichen Verbesserung gilt Artikel 366 Absatz 2 sinngemäss.²⁵⁷
			^{2bis} Eine zum Voraus getroffene Verabredung, wonach der Anspruch auf unentgeltliche Verbesserung eingeschränkt oder ausgeschlossen wird, ist ungültig, wenn der Mangel eine Baute betrifft.²⁵⁸ ³ Bei Werken, die auf dem Grund und Boden des Bestellers errichtet sind und ihrer Natur nach nur mit unverhältnismässigen Nachteilen entfernt werden können, stehen dem Besteller nur die im zweiten Absatz dieses Artikels genannten Rechte zu.

6.2.2. Folgen bei Mängel

- **Wandelung (Art. 368 Abs. 1 OR):** Rücktritt bei erheblichen Mängeln oder starker Vertragsabweichung, wenn Annahme unzumutbar ist.
 - ▶ Bei fest mit Grundstück verbundenem Werk nur, wenn die Beseitigung keine unverhältnismässigen Nachteile bringt.
- **Minderung (Art. 368 Abs. 2 OR):** Werklohn wird nach dem Minderwert gekürzt.
 - ▶ Berechnung nach relativer Methode; Minderwert kann den Kosten einer Ersatzvornahme entsprechen.
- **Nachbesserung (Art. 368 Abs. 2 OR):** Besteller kann Verbesserung verlangen, wenn sie möglich ist und keine übermässigen Kosten verursacht.
 - ▶ Übermässig, wenn Kosten und Nutzen der Mängelbeseitigung in einem Missverhältnis stehen.
- **Schadenersatz:** Zusätzlich zu Wandelung, Minderung oder Nachbesserung möglich, wenn den Unternehmer ein vermutetes Verschulden trifft.

6.3. Verzug (Art. 366 sowie 102 OR)

Falls der Unternehmer im Verzug ist, kann der Besteller vorzeitig vom Vertrag zurücktreten.

- Art. 97 ff. OR -> falls Fertigstellung des Werkes unmöglich wird
- **Ersatzvornahme** nach Art. 366 Abs. 2 OR möglich, wenn:
 - mangelhafte oder vertragswidrige Herstellung voraussehbar ist
 - Unternehmer verschuldet handelt, ohne Selbstverschulden des Bestellers
 - angemessene Frist mit Androhung der Ersatzvornahme gesetzt wurde
- Alternativ kann der Besteller nach Art. 107 Abs. 2 OR vom Vertrag zurücktreten.
- Art. 377 OR -> solange unvollendet kann zurückgetreten werden

6.4. Art. 365 OR - Betreffend den Stoff

¹ **Soweit der Unternehmer die Lieferung des Stoffes übernommen hat, haftet er dem Besteller für die Güte desselben und hat Gewähr zu leisten wie ein Verkäufer.**
(Sachgewährleistung)

² **Den vom Besteller gelieferten Stoff hat der Unternehmer mit aller Sorgfalt zu behandeln, über dessen Verwendung Rechenschaft abzulegen und einen allfälligen Rest dem Besteller zurückzugeben.**

³ **Zeigen sich bei der Ausführung des Werkes Mängel an dem vom Besteller gelieferten Stoffe oder an dem angewiesenen Baugrunde, oder ergeben sich sonst Verhältnisse, die eine gehörige oder rechtzeitige Ausführung des Werkes gefährden, so hat der Unternehmer dem Besteller ohne Verzug davon Anzeige zu machen, widrigenfalls die nachteiligen Folgen ihm selbst zur Last fallen.** (Orientierungspflicht)

7. Auftrag

7.1. Auftragsarten

- **Einfacher Auftrag (Art. 394 ff. OR)**
- **Ehe-/Partnerschaftsvermittlung (Art. 406a OR):** Vermittlung von Personen für Ehe oder feste Partnerschaft gegen Vergütung.
- **Kreditbrief/Kreditauftrag:** Beauftragter gewährt einem Dritten Kredit.
- **Mäklervertrag:** Vermittlung oder Nachweis einer Vertragsgelegenheit gegen Vergütung (Art. 412 Abs. 1 OR).
- **Agenturvertrag:** Dauerhafte Vermittlung oder Abschluss von Geschäften für Auftraggeber ohne Arbeitsverhältnis (Art. 418a OR).

7.2. Annahme des Auftrags (Art. 394 OR)

- Kann formfrei geschlossen werden
- Auftrag vertragsgemäss ausführen, Erfolg jedoch nicht geschuldet (jedoch anstreben)
- Mögliche Gegenstände eines Auftrages: jegliche persönliche Handlungen
- Voraussetzung eines Auftrages: Tätigwerden in fremden Interesse
- Der Auftrag kann sowohl **Rechtshandlung**: Handlung mit rechtlicher Wirkung, z.B. Vertragsschluss, als auch **Tathandlung**: tatsächliche Handlung ohne unmittelbaren Rechtsakt, z.B. Beratung oder Behandlung, betreffen.
- Er dient als **Auffangvertrag**: Vertragstyp für Dienstleistungen, die keinem Spezialvertrag zugeordnet sind.

- Beispiele: medizinische Behandlung, anwaltliche Beratung, Steuerberatung, Finanzberatung oder Unternehmensberatung.

7.3. Sorgfaltspflicht und Treuepflicht (Art. 398 OR)

- Beauftragter haftet für getreue und sorgfältige Ausführung.
 - Massstab: konkrete Umstände und fachtypisches Durchschnittsverhalten.
 - Verschulden bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Sorgfaltspflichtverletzung.
- Treuepflicht: Interessen des Auftraggebers wahren.
 - Beraten, informieren (auch über **Interessenkollision**: Konflikt zwischen eigenen Interessen und Interessen des Auftraggebers) und Geheimhaltung beachten.
 - Beauftragter muss die nötigen Fähigkeiten und persönlichen Eigenschaften besitzen.

7.4. Rechenschaftspflicht und Herausgabepflicht (Art. 400 OR)

- Beauftragter muss jederzeit auf Verlangen Rechenschaft ablegen.
- Alles, was er aus der Geschäftsführung erhalten hat, ist dem Auftraggeber herauszugeben.

- **Art. 400**

¹ Der Beauftragte ist schuldig, auf Verlangen jederzeit über seine Geschäftsführung Rechenschaft abzulegen und alles, was ihm infolge derselben aus irgendeinem Grunde zugekommen ist, zu erstatten.

7.5. Beendigung des Auftrags (Art. 404 OR)

- Auftrag kann jederzeit von beiden Parteien widerrufen oder gekündigt werden.
- Kündigungsrecht ist zwingend.
- **Kündigung zur Unzeit:** Kündigung zu besonders ungünstigem Zeitpunkt mit besonderen Nachteilen für die andere Partei, führt zu Schadenersatzpflicht.

8. Haftpflichtrecht

8.1. Ausserververtragliche Haftung

8.1.1. Verschuldenshaftung (Art. 41 OR)

- Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum

Ersatze verpflichtet.

- Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.

Voraussetzungen:

- Schaden (unfreiwillige Vermögenseinbusse)
- **Adäquater Kausalzusammenhang** (Zusammenhang von schuldhaftem Verhalten und Schaden)
- Widerrechtlichkeit (Verletzung der Persönlichkeit oder Eigentum ohne Rechtsgrund)
- Verschulden (Fahrlässigkeit oder Vorsatz)

8.1.2. Kausalhaftung

Verschulden ist nicht erforderlich oder es wird vermutet. Bei der milden Kausalhaftung steht dem Schädiger die Möglichkeit offen, sich zu entlasten (**Sorgfaltsbeweis**). Bei der scharfen Kausalhaftung ist dies nicht möglich.

8.1.2.1. Milde Kausalhaftung

- Haftung ohne erforderliches Verschulden, wenn ein Schaden durch unsorgfältiges Verhalten oder eine zurechenbare Verantwortlichkeit entsteht
- Es genügt eine Sorgfaltswidrigkeit, sie muss nicht bereits eine schuldhafte Pflichtverletzung sein
- Beispiele: Geschäftsherrenhaftung, Tierhalterhaftung, Haftung des Familienoberhauptes, Produktheftpflicht

8.1.2.2. Scharfe Kausalhaftung

- Haftung auch ohne Ordnungswidrigkeit oder Verschulden.
- Verantwortlicher haftet selbst bei ordnungsgemäsem Unterhalt/Pflege, wenn der Schaden kausal zurechenbar ist.
- Beispiel: Werkeigentümerhaftung.
- **Befreiungsbeweis** möglich: fehlender Kausalzusammenhang.

8.1.3. Gefährdungshaftung

Qualifizierte Gefährdung durch Vorrichtung oder Tätigkeit.

Haftung entsteht schon durch den Betrieb einer gefährlichen Sache oder Tätigkeit, auch ohne Verschulden. Beispiele: Motorfahrzeug, Flugzeug, Jagd oder Atomanlage.

8.1.4. Vertragliche Haftung (Art. 197 OR)

Der Verkäufer haftet dafür, dass die Kaufsache die zugesicherten Eigenschaften hat und keine erheblichen körperlichen oder rechtlichen Mängel aufweist. Er haftet auch, wenn er den Mangel nicht kannte.

- Voraussetzungen:
- Schaden
- Vertragsverletzung
- Verschulden: Ist nicht erforderlich oder es wird vermutet
- Kausalzusammenhang

8.2. Produkthaftungspflicht (Grundsatz) (Art. 1, 2, 4 PrHG)

Art. 1 PrHG

¹ Die herstellende Person (Herstellerin) haftet für den Schaden, wenn ein **fehlerhaftes Produkt** (Kausalhaftung) dazu führt, dass:

- a. eine Person getötet oder verletzt wird; (Personenschaden)
- b. eine Sache beschädigt oder zerstört wird, die nach ihrer Art gewöhnlich zum privaten Gebrauch oder Verbrauch bestimmt und vom Geschädigten hauptsächlich privat verwendet worden ist. (Sachschaden)

² Die Herstellerin haftet **nicht** für den Schaden am fehlerhaften Produkt. (Führt bspw. ein fehlerhaftes Kletterseil zu einem Sportunfall, geht es vorliegend nicht um den Ersatz des fehlerhaften Produktes.)

Art. 2 PrHG

¹ Als Herstellerin im Sinne dieses Gesetzes gilt:

- a. die Person, die das Endprodukt, einen Grundstoff oder ein Teilprodukt hergestellt hat;
- b. jede Person, die sich als **Herstellerin ausgibt**, indem sie ihren Namen, ihr Warenzeichen oder ein anderes Erkennungszeichen auf dem Produkt anbringt;
- c. jede Person, die ein Produkt zum Zweck des Verkaufs, der Vermietung, des Mietkaufs oder einer andern Form des Vertriebs im Rahmen ihrer geschäftlichen Tätigkeit einführt; dabei bleiben abweichende Bestimmungen in völkerrechtlichen Verträgen vorbehalten

² Kann die Herstellerin des Produkts nicht festgestellt werden, so gilt jede Person als Herstellerin, welche das **Produkt geliefert hat**, sofern sie dem Geschädigten nach einer entsprechenden Aufforderung nicht innerhalb einer angemessenen Frist die Herstellerin oder die Person nennt, die ihr das Produkt geliefert hat.

• Art. 4 PrHG

¹ Ein Produkt ist **fehlerhaft**, wenn es nicht die Sicherheit bietet, die man unter **Berücksichtigung aller Umstände zu erwarten berechtigt ist**; insbesondere sind zu berücksichtigen:

- a. die **Art und Weise**, in der es dem Publikum präsentiert wird;
- b. der Gebrauch, mit dem **vernünftigerweise** gerechnet werden kann;

[WCB 200-DE-de](#)

- c. der **Zeitpunkt**, in dem es in Verkehr gebracht wurde.



² Ein Produkt ist nicht allein deshalb fehlerhaft, weil später ein verbessertes Produkt in Verkehr gebracht wurde.

- Siehe hierfür auch das Bundesgesetz über die Produktesicherheit (PrSG) über die Voraussetzungen für das Inverkehrbringen von Produkten (Art. 3ff. PrSG). Link: [Microsoft Word - 930.11.de.doc \(admin.ch\)](#)
- Gemäss PrSG haben alle Produkte, welche im gewerblichen oder beruflichen Bereich benutzt werden, **Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen** zu entsprechen.
 - Einige Aspekte sind: Voraussichtliche Gebrauchsdauer und Art der Verwendung, Einwirkung auf andere Produkte, Personen die einer grösseren Gefahr ausgesetzt sind

8.2.1. Fehlerbegriff

BGE 133 III 81: Eine gläserne Kaffeekanne explodierte plötzlich und verletzte die Konsumentin schwer. Bei der Produkthaftung musste sie nicht genau beweisen, warum die Kanne explodierte. Es genügte, dass sie zeigte, dass die Kaffeekanne nicht den berechtigten Sicherheitserwartungen eines durchschnittlichen Konsumenten entsprach.

Da es sich um eine Kausalhaftung handelt, kann sich der Hersteller oder Importeur nicht einfach mit sorgfältigem Verhalten entlasten. Der Ablauf wird nach überwiegender Wahrscheinlichkeit beurteilt.

8.2.2. Voraussetzungen

Hersteller haftet, wenn:

1. Er ist Hersteller / Importeur / Händler nach Art. 2 PrHG
2. Es handelt sich um ein Produkt nach Art. 3 PrHG
3. Es ist im Sinne von Art. 4 PrHG fehlerhaft
4. Es verursachte einen Schaden im Sinne von Art. 1 PrHG und der Schaden ist grösser als der Selbstbehalt von CHF 900.00 (Art. 6 Abs. 1 PrHG)
5. Zwischen dem fehlerhaften Produkt und dem Schaden besteht überdies ein adäquater Kausalzusammenhang nach Art. 1 PrHG

Merke: Vereinbarungen, welche die Haftpflicht nach diesem Gesetz gegenüber dem Geschädigten beschränken oder wegbedingen, sind nichtig (Art. 8 PrHG). Verjährungsfrist beträgt drei Jahre (Art. 9 PrHG) und die Verwirkungsfrist zehn Jahre (Art. 10 PrHG)

8.2.3. Ausnahmen von der Haftung

Hersteller kann sich aus folgenden Gründen exkulpieren:

- Produkt nicht in Verkehr gebracht;
- Fehler bei Inverkehrsetzung noch nicht vorhanden;
- Produkt für den Verkauf oder eine Art des Vertriebs mit wirtschaftlichem Zweck oder im Rahmen der beruflichen Tätigkeit hergestellt bzw. vertrieben;
- Fehler ist darauf zurück zu führen, dass das Produkt verbindlichen, hoheitlich erlassenen Vorschriften entspricht;
- Fehler konnte nach dem Stand der Wissenschaft und Technik im Zeitpunkt, in dem das Produkt in Verkehr gebracht wurde, nicht erkannt werden (Beachte Ausnahmen nach Art. 5 Abs. 1bis PrHG).
- Eine Ausnahme besteht auch für den Hersteller eines Grundstoffs oder eines Teilprodukts, wenn der Fehler erst mit der weiteren Verarbeitung entstanden ist.

8.2.4. Anwendungsfälle

- Fehlerhaftigkeit von Geräten oder Maschinen oder andere Arbeitsmittel auf Baustellen oder in der Industrie
- Fehlerhafte Glasskane explodiert bei Überhitzung
- Kletterseil hält nicht bei vorgesehener Belastungsgrenze
- Rahmenbruch bei einem Fahrrad
- Explosion einer Sektflasche
- Notebook geht, aufgrund eines fehlerhaften Akkus, in Flammen auf.
- Greifer einer Anlage griffen aufgrund einer fehlerhaften Dimensionierung nicht.

Weiter: Bruchige Schrauben, falscher Stahl, gefährliche Fehlkonstruktionen, missverständliche Bedienungsanleitungen, fehlende Sicherheitshinweise, mit Bakterien verseuchte oder verunreinigte Lebensmittel etc.

Weitere konkrete Fälle waren unter anderem fehlerhafte Hüftprothesen, ein verletzender BMW-Airbag, das Medikament Contergan, zuckerhaltiger Kindertee mit ungeeigneter Nuckelflasche und eine Veet-Haarentfernungscreme, die trotz korrekter Anwendung einen Ausschlag verursachte.

9. Fallbeispiele

9.1. Obligationenrecht

9.1.1. Fall 1: Zerbrochene Vase im Möbelhaus

Sachverhalt: Petra nimmt in einem Möbelhaus eine grosse, farbige Blumenvase unter den Arm und geht damit zur Kasse. Auf der Rolltreppe fällt die Vase zu Boden und zerbricht.

Frage: Auf welche Rechtsgrundlage könnte Ikea einen Anspruch stützen?

Lösung: In Betracht kommt Art. 97 OR wegen Ausbleibens bzw. Schlechterfüllung der Leistung. Ist jedoch nicht 100% ob sie wirklich kaufen wollte.

Besser passt deshalb Art. 41 Abs. 1 OR: Petra hat durch ihr Verhalten die Vase beschädigt. Wenn sie die grosse Vase unvorsichtig unter den Arm nimmt, statt z. B. einen Einkaufswagen zu benutzen, könnte das als fahrlässig gelten. Ikea hätte dann einen Schaden in Höhe des Werts der zerbrochenen Vase. Art. 41 OR verlangt Schaden, Widerrechtlichkeit, Kausalzusammenhang und Verschulden.

9.1.2. Fall 2: Bestelltes Mobiltelefon

Sachverhalt: Hans interessiert sich in einem Fachgeschäft für ein bestimmtes Mobiltelefon, das vor Ort nicht erhältlich ist. Auf Wunsch von Hans bestellt die Verkäuferin das Gerät. Hans verspricht, es abzuholen, kauft später aber dasselbe Telefon bei der Konkurrenz und meldet sich nicht mehr.

Frage: Wie ist die Rechtslage?

Schuldner und Gläubiger:

Pflicht	Schuldner	Gläubiger
Lieferung / Bereitstellung des Mobiltelefons	Fachgeschäft / Verkäuferin	Hans
Zahlung des Kaufpreises und Abholung	Hans	Fachgeschäft / Verkäuferin

Lösung: Hans hat im Fachgeschäft ein bestimmtes Mobiltelefon gewollt. Die Verkäuferin hat es auf seinen Wunsch bestellt und gesagt, dass Hans ein Mail erhält, sobald er es abholen kann. Hans hat versprochen, es dann abzuholen. Damit liegen Antrag und Annahme vor. Der Kaufvertrag entsteht nach Art. 1 OR durch übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung. Beim Kaufvertrag verpflichtet sich der Verkäufer zur Übergabe der Sache und der Käufer zur Bezahlung des Kaufpreises, Art. 184 OR.

9.1.3. Fall 3: Falscher Gesamtpreis in der Offerte

Sachverhalt: X bringt sein Auto in die Garage Z. Z offeriert die Reparatur zu CHF 1'725.80. Die detaillierte Aufstellung ergibt aber Arbeit von 10h à CHF 130.– plus Ersatzmaterial von CHF 525.80. X nimmt das Angebot an.

Frage: Wie viel schuldet X nach der Reparatur?

Lösung: X schuldet grundsätzlich CHF 1'725.80, weil dieser Preis offeriert und von X angenommen wurde. Es liegt ein Vertragsschluss durch Antrag und Annahme nach Art. 1 OR vor.

Es könnte sich zudem um einen Erklärungsirrtum nach Art. 24 Abs. 1 Ziff. 3 OR handeln. Z wollte gemäss detaillierter Aufstellung eigentlich CHF 1'825.80 verlangen, hat aber im Gesamtpreis versehentlich CHF 1'725.80 angegeben. Damit hat Z möglicherweise etwas anderes erklärt, als er

erklären wollte. Falls der Irrtum wesentlich ist und Z sich rechtzeitig darauf beruft, könnte der Vertrag für Z unverbindlich sein. Unter Umständen müsste Z aber Schadenersatz leisten, wenn ihn am Irrtum ein Verschulden trifft, Art. 26 OR.

9.1.4. Fall 4: Verkauf der Kakteensammlung

Sachverhalt: Franz ist stark verschuldet und braucht dringend CHF 20'000.–. Bert kennt diese Situation und bietet Franz CHF 22'000.– für einen Teil seiner seltenen Kakteensammlung, obwohl die Sammlung bei sorgfältigem Verkauf mindestens den zwei- bis dreifachen Preis erzielen könnte. Franz nimmt widerwillig an.

Frage: Kann Franz etwas tun?

Lösung: Franz kann gegenüber Bert erklären, dass er den Vertrag wegen Übervorteilung nach Art. 21 OR nicht halten will. Dann muss er die Kakteensammlung nicht aushändigen. Falls er schon etwas erhalten hätte, müsste das bereits Geleistete zurückgegeben werden.

Dass Franz später durch Börsenspekulationen wieder zu Geld kommt, ändert daran grundsätzlich nichts. Entscheidend ist die Situation beim Vertragsschluss.

9.1.5. Fall 5: Occasions-Sportwagen mit manipuliertem Kilometerstand

Sachverhalt: Hans kaufte am 5.7.2023 von Willy einen Occasions-Sportwagen. Willy hatte das Auto kurz zuvor von Thomas gekauft. Thomas hat den Kilometerstand manipuliert, wovon Hans und Willy nichts wussten. Am 7.1.2024 erfährt Hans durch das Strassenverkehrsamt von der Manipulation.

Frage: Wie ist die Rechtslage?

Lösung: Zwischen Hans und Willy besteht ein Kaufvertrag nach Art. 184 ff. OR. Der manipulierte Kilometerstand ist ein Sachmangel. Da Thomas manipuliert hat und Willy davon nichts wusste, kann Hans den Vertrag gegenüber Willy grundsätzlich nicht wegen absichtlicher Täuschung nach Art. 28 OR anfechten.

Hans kann aber kaufrechtliche Gewährleistungsrechte geltend machen, z. B. Wandelung oder Minderung nach Art. 205 OR. Dafür muss er den Mangel nach der Entdeckung am 7.1.2024 unverzüglich rügen, Art. 201 OR.

Variante 1: Hat Willy selbst manipuliert, liegt absichtliche Täuschung nach Art. 28 OR vor. Hans kann den Vertrag anfechten; die Jahresfrist nach Art. 31 OR läuft ab Entdeckung.

Variante 2: Reagiert Hans erst im Herbst 2024, ist die Rüge nach Art. 201 OR wahrscheinlich verspätet. Dann gilt das Auto als genehmigt und Hans verliert seine kaufrechtlichen Mängelrechte.

9.1.6. Fall 6: Halskette gefällt nicht

Sachverhalt: Peter kauft beim Juwelier eine Halskette als Geburtstagsgeschenk für seine Frau. Ihr gefällt die Halskette nicht, und Peter möchte sie zurückgeben.

Frage: Ist das möglich?

Lösung: Grundsätzlich nein, Peter kann die Halskette nicht einfach zurückgeben, nur weil sie seiner Frau nicht gefällt.

Zwischen Peter und dem Juwelier ist ein gültiger Kaufvertrag zustande gekommen. Der Juwelier schuldet die Übergabe der Halskette, Peter schuldet den Kaufpreis, Art. 184 OR. Wenn die Halskette mangelfrei ist, gibt es kein gesetzliches Rückgaberecht. Ein Nichtgefallen ist kein Sachmangel nach Art. 197 OR.

9.1.7. Fall 7: Vertauschte Preisschilder

Sachverhalt: Die Inhaberin eines Uhrengeschäfts verwechselt in der Auslage zwei Preisschilder. Die Rolex ist mit dem Preis der Swatch für CHF 129.– angeschrieben, die Swatch mit dem Preis der Rolex von CHF 9'890.–.

Frage: Was kann die Inhaberin tun, wenn ein Käufer die Rolex für CHF 129.– kaufen möchte?

Lösung: Die Inhaberin muss die Rolex nicht einfach für CHF 129.– verkaufen.

Grund: Die Auslage einer Ware mit Preisangabe gilt zwar nach Art. 7 Abs. 3 OR grundsätzlich als Antrag. Normalerweise könnte der Käufer also sagen: „Ich nehme die Rolex für CHF 129.–.“

Hier liegt aber ein offensichtlicher Fehler vor: Eine Rolex für CHF 129.– ist extrem unrealistisch, während gleichzeitig die Swatch mit CHF 9'890.– angeschrieben ist. Die Inhaberin kann sich deshalb auf einen wesentlichen Irrtum, genauer einen Erklärungsirrtum nach Art. 24 OR, berufen. Sie hat nicht den Willen gehabt, die Rolex für CHF 129.– zu verkaufen, sondern hat die Preisschilder versehentlich vertauscht.

9.2. ZGB

Art. 8 ZGB = Wer muss was beweisen?

Art. 4 ZGB = Gericht hat gesetzlichen Ermessensspielraum. (muss entscheiden)

Art. 3 ZGB = Schützt den guten Glauben einer Person.

Art. 2 ZGB = Verbietet treuwidriges Verhalten.

Sachverhalt	Art.	Kurzbegründung
Roman kauft auf dem Parkplatz einer Raststätte von einer Privatperson drei Stangen Zigaretten zum halben Preis.	Art. 3 ZGB	Guter Glaube ist fraglich: Parkplatz, Privatperson und halber Preis hätten Roman misstrauisch machen müssen.
Roman wurde zu unrecht fristlos entlassen. Der Richter setzt nun eine Entschädigung zwischen einem und sechs Monatslöhnen fest.	Art. 4 ZGB	Das Gesetz gibt dem Richter einen Rahmen. Innerhalb dieses Rahmens entscheidet er nach richterlichem Ermessen.
Peter kündigt seiner Mieterin formal korrekt, nur um sie zu ärgern, da er gar nicht beabsichtigt, die Wohnung selbst zu nutzen oder weiterzuvermieten.	Art. 2 Abs. 2 ZGB	Das ist Rechtsmissbrauch. Die Kündigung ist zwar formal korrekt, wird aber zweckwidrig und schikanös eingesetzt.
Herr Müller verkauft seinem Nachbarn ein Stück Land. Im Kaufvertrag wird der Grenzverlauf ungenau eingezeichnet. Müller weiss, dass der Nachbar die Grenze missverstanden hat, schweigt aber bewusst.	Art. 2 Abs. 1 ZGB	Müller handelt gegen Treu und Glauben, weil er den Irrtum erkennt und bewusst schweigt.
Maria behauptet, sie habe ihrem Freund Jonas 500 Franken geliehen. Jonas bestreitet dies.	Art. 8 ZGB	Maria muss beweisen, dass sie Jonas die CHF 500 geliehen hat.
Tom kauft in einem Second-Hand-Laden eine wertvolle Uhr. Der Preis ist zwar günstig, aber	Art. 3 ZGB	Da der Kauf in einem Second-Hand-Laden erfolgt und der

nicht völlig auffällig. Später stellt sich heraus, dass die Uhr gestohlen war.		Preis nicht extrem auffällig ist, könnte Tom gutgläubig gewesen sein.
Eine Konsumentin kauft einen neuen Laptop. Nach zwei Monaten funktioniert er plötzlich nicht mehr. Die Verkäuferin behauptet: „Der Laptop war bei der Übergabe in Ordnung, Sie müssen ihn unsachgemäss behandelt haben.“	Art. 8 ZGB	Es geht um Beweislast: Die Konsumentin muss den Mangel bzw. ihre Gewährleistungsansprüche beweisen.
Ein Schreiner verpflichtet sich vertraglich, für die Kundin Sophie bis zum 1. Mai einen Esstisch zu liefern. Der Tisch wird nicht geliefert. Sophie verlangt Schadenersatz für die Kosten, die ihr durch die Miete eines Ersatzmöbels entstanden sind. Der Schreiner sagt: „Ich konnte den Tisch wegen einer plötzlichen Holzknappheit nicht rechtzeitig fertigstellen, daran bin ich nicht schuld.“	Art. 8 ZGB	Sophie beweist Vertrag, Nichtlieferung und Schaden; der Schreiner fehlendes Verschulden.

9.3. Arbeitsrecht

Nr.	Fall	Kurzlösung
1	Wie kann ein unbefristeter Arbeitsvertrag beendet werden?	Ein unbefristeter Arbeitsvertrag kann von beiden Parteien ordentlich gekündigt werden. Auf Verlangen ist die Kündigung schriftlich zu begründen. Grundlage: Art. 335 OR .
2	Ein leitender Angestellter der Protec AG muss wegen Ausfall eines Mitarbeiters mehr arbeiten. Kann er ohne Regelung im Arbeitsvertrag Überstundenentschädigung verlangen?	Leitende Angestellte sind vom ArG weitgehend ausgenommen. Bei echten höheren leitenden Angestellten ist Mehrarbeit oft durch Lohn und Stellung abgegolten. Ein Anspruch besteht daher nicht automatisch. Grundlage: Art. 3 ArG, Art. 321c OR .
3	Welche Arbeitnehmer- und Arbeitgeberpflichten ergeben sich aus dem OR?	Arbeitnehmer: Arbeitspflicht, Treuepflicht, Sorgfaltspflicht, Weisungsbefolgung, Geheimhaltung, Überstunden. Arbeitgeber: Lohnzahlung, Fürsorgepflicht, Ferien, Arbeitszeugnis, Auslagenersatz. Grundlage: Art. 321 ff. OR, Art. 322 ff. OR .
4	Peter Meier arbeitet seit 25 Jahren bei der X. AG. Nach einem zweimonatigen Klinikaufenthalt wegen Burnout will der Arbeitgeber seinen Ferienanspruch um 1/6 kürzen. Ist das zulässig?	Die Kürzung um 1/6 ist nicht zulässig. Bei Krankheit darf der Ferienanspruch erst nach einem Monat Schonfrist gekürzt werden. Bei zwei Monaten Krankheit höchstens um 1/12 . Grundlage: Art. 329b OR .
4 Zusatz	Peter droht, sich an den Kassensturz zu wenden. Der Arbeitgeber weist ihn auf die	Die Geheimnispflicht betrifft Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse, z.B. Kundenlisten, Kalkulationen, Rezepte oder

	zivil- und strafrechtliche Geheimnispflicht hin. Was bedeutet diese im Arbeitsrecht?	Strategien. Nicht jede Kritik am Arbeitgeber ist eine Geheimnisverletzung. Grundlage: Art. 321a Abs. 4 OR.
5	Was hat eine gerechtfertigte fristlose Kündigung für Konsequenzen?	Bei gerechtfertigter fristloser Kündigung endet das Arbeitsverhältnis sofort. Die kündigende Partei muss keine Kündigungsfrist einhalten und kann bei Verschulden Schadenersatz verlangen. Grundlage: Art. 337 ff. OR.
6	Maria Meister und der CEO der Z. AG möchten künftig bei Krankheit nur noch das gesetzliche Minimum statt vier Monate Lohnfortzahlung bezahlen. Wie können die Arbeitsverträge geändert werden?	Arbeitsverträge können nicht einseitig geändert werden. Möglich sind ein Änderungsvertrag oder eine Änderungskündigung mit Einhaltung der Kündigungsfrist. Das gesetzliche Minimum der Lohnfortzahlung muss eingehalten werden. Grundlage: Art. 324a OR.
7	Klara Kleiner wird wegen fehlerhafter Buchungen und Überweisungen auf ein Privatkonto fristlos gekündigt. Später zeigt sich, dass ihre Kollegin dafür verantwortlich war. Wie kann Klara vorgehen?	Da kein wichtiger Grund vorlag, ist die fristlose Kündigung ungerechtfertigt. Klara kann Lohn bis zum Ende der ordentlichen Kündigungsfrist, Schadenersatz und eine Entschädigung bis zu sechs Monatslöhnen verlangen. Grundlage: Art. 337c OR.
8a	Was sind wichtige Gründe für eine fristlose Kündigung?	Wichtige Gründe sind schwere Pflichtverletzungen, z.B. Diebstahl, Betrug, Gewalt, Drohungen, Arbeitsverweigerung, Geheimnisverrat oder Konkurrenzierung. Grundlage: Art. 337 OR.
8b	Was sind Beispiele einer missbräuchlichen Kündigung?	Missbräuchlich sind z.B. Rachekündigung, Kündigung wegen persönlicher Eigenschaften, wegen Ausübung von Rechten oder zur Vereitelung von Ansprüchen. Die Kündigung bleibt gültig, kann aber Entschädigung auslösen. Grundlage: Art. 336 OR.
9	Mitarbeiter B kann Arbeitszeit und Ferien frei einteilen. In der Lohnabrechnung steht, dass mit der Lohnzahlung alle Ferienansprüche abgegolten sind. Ist das zulässig?	Ferien müssen grundsätzlich bezogen werden und dürfen nicht einfach mit dem Lohn abgegolten werden. Ausnahme bei unregelmässigem Pensum, wenn der Ferienlohn klar separat ausgewiesen wird. Üblich: 8.33% bei 4 Wochen, 10.64% bei 5 Wochen.
10	Fritz Müller kündigt auf Ende Januar, unterschreibt einen neuen unbefristeten Arbeitsvertrag ab 1. Juni und wird im Mai für zwei Monate arbeitsunfähig. Muss der neue Arbeitgeber Lohn zahlen?	Die Probezeit ist nicht entscheidend. Bei einem unbefristeten Vertrag besteht bei unverschuldeter Arbeitsunfähigkeit grundsätzlich Lohnfortzahlung ab Stellenantritt. Im ersten Dienstjahr

	mindestens drei Wochen. Grundlage: Art. 324a OR.
--	---

9.4. Diverse Fälle

• Gibt es bei Einzelarbeitsverträgen auch Formvorschriften zu beachten? • Die Vertragspunkte eines Gesamtarbeitsvertrages dürfen einen Arbeitnehmer keinesfalls schlechter stellen als die Vorschriften im Obligationenrecht, korrekt? • Welchen Anforderungen muss ein Arbeitszeugnis grundsätzlich entsprechen? Wo sehen Sie allenfalls Zielkonflikte? • Bei der Haftung des Arbeitnehmers gemäss Art. 321e OR kann man den Arbeitnehmer auch mehr in die Pflicht nehmen, als es das OR vorsieht, korrekt? • Die Überstunden kann man insgesamt wegbedingen, die Überzeit hingegen nicht, korrekt? • Wenn der Arbeitnehmer in einer Sperrfrist kündigt, ist die Kündigung nichtig, korrekt? • Bei der missbräuchlichen Kündigung muss man einen gewissen Ablauf berücksichtigen, welchen? • Ein Werkvertrag kann formfrei geschlossen werden, korrekt? • Wie muss der Besteller vorgehen, wenn er das Werk entgegennimmt? Was muss er tun, wenn er Mängel entdeckt? Welche Möglichkeiten hat er dann? • Handelt es sich bei der Reparatur eines Klaviers um einen Auftrag oder um einen Werkvertrag? Begründen Sie kurz anhand der Ihnen bekannten Abgrenzungskriterien. • Auch nach mehrfacher Ermahnung verzögert der Unternehmer die Bauarbeiten unbegründet. Was kann der Besteller hier machen? • Der Anwalt weigert sich kurz vor der Verhandlung, das Mandat niederzulegen. Er ist der Meinung, dass er bereits alle Vorbereitungshandlungen gemacht habe und so kurzfristig keinen neuen Klienten mehr finden würde. Der Klient ist da anderer Meinung. Wer hat Recht?

Roman kauft bei einem Sportfachgeschäft ein Kletterseil. Dieses soll gemäss Angaben des Herstellers (Alternativ des Verkäufers) ca. 1000 Kilogramm Gewicht tragen können. Leider reisst das Seil aber beim Klettern bereits nach einer Last von 50 Kilogramm ab. Bei der Begutachtung und der Ermittlung des Sachverhalts stellt sich heraus, dass dieses Seil: a. einen Materialfehler hat; b. bereits beim Kauf beschädigt worden sein muss; c. Irrtümlicherweise vom Verkäufer empfohlen worden ist und gar kein Kletterseil war.

Roman ist Unternehmer und auf das Herstellen von individuell gefertigten Haushaltsgeräten spezialisiert. Klar das diese sehr teuer sind, aber er verspricht den Kunden eine top Qualität. Peter ist bei der Unternehmung von Roman als Entwickler angestellt und ist dort der kreative Kopf. Leider meint es Peter nicht gut mit Roman und er plant dem Unternehmen zu schaden. Aus diesem Grund sabotiert er einige Geräte, wie einen Kühlschrank, eine Waschmaschine und einen Kochherd. Davon bekommt Roman nichts mit, und er händigt diese Produkte seinen Kunden aus. Einige Tage später hört er von einem schweren Zwischenfall in der Küche eines Kunden. Dieser hat sich aufgrund eines Brandes in der Küche schwer am ganzen Körper verletzt und die Küche ist total abgebrannt. Die Rechtsabteilung von Roman empfiehlt ihm, sofort einen Anwalt zu konsultieren. Gesagt getan. Auch die Frau des verletzten Kunden hat bereits einen Anwalt. Während den aussergerichtlichen Verhandlungen kommt heraus, dass Peter für diesen Kurzschluss in der Küche verantwortlich war. Es ist zwar unklar, ob er das absichtlich gemacht hat oder nicht, aber es lässt Roman nicht mehr in Ruhe und er entlässt Peter, auf Empfehlung seines Anwalts fristlos. Nun hat sich auch Peter einen Anwalt genommen, um gegen die «ungerechtfertigte» fristlose Kündigung vorzugehen. Er stellt beträchtliche Forderungen. Roman weiss nicht mehr, wo ihm der Kopf steht. Da er auch seinem Anwalt nicht mehr ganz traut, kommt er schliesslich zu Ihnen, um von Ihnen eine Zweitmeinung einzuholen. Ziehen Sie für die Beratung alle Register und prüfen Sie alle möglichen Ansprüche (Arbeitsvertrag, Werkvertrag, Auftrag, Produkthaftpflicht und andere ausservertraglichen Haftungsgrundlagen).

Roman, den Sie mittlerweile bestens kennen sollten, hat sich bei einem Anwalt beraten lassen, wie er am besten in einer arbeitsrechtlichen Streitigkeit vorgehen soll. Folgende Problematik hatte er an seinem Arbeitsplatz: Der Arbeitgeber hat ihm im ersten Dienstjahr aber nach Ablauf der Probezeit

fristlos gekündigt. Das Problem ist aber, dass er zu diesem Zeitpunkt für fünf Tage krankgeschrieben war. Er ist der Meinung, dass diese Kündigung nichtig sei und er demnach noch angestellt sei. Grund der fristlosen Kündigung sei eine falsche Deklaration der Arbeitszeiten gewesen. Roman bestreitet dies aber vehement. Der Anwalt ist da gleicher Meinung und geht in diesem Sinne gegen den Arbeitgeber vor. Er fordert ihn auf, Roman wieder anzustellen, da die Kündigung nichtig sei. Der Arbeitgeber ist da anderer Meinung und bricht den Kontakt ab. In der Folge muss der Anwalt den Klageweg beschreiten. Nach erfolgloser Schlichtung und Klageabweisung bei Gericht, stellt der Anwalt dem Roman eine Honorarnote von CHF 10'000.00 CHF zu. Roman ist verärgert und möchte diese nicht bezahlen.

Glossar

Begriff	Fundstelle
Natürliche Personen	Seite 8
Juristische Personen	Seite 8
Culpa in contrahendo	Seite 8
Vertragsfreiheit	Seite 9
Dispositive Gesetzesbestimmungen	Seite 9
Zwingende Gesetzesbestimmungen	Seite 9
Formfreiheit	Seite 10
Willensäußerung	Seite 11
Antrag	Seite 11
Annahme	Seite 11
Nichterfüllung	Seite 13
Gläubigerverzug	Seite 13
Positive Vertragsverletzung	Seite 13
Schuldnerverzug	Seite 13
Fälligkeit	Seite 15
Erfüllbarkeit	Seite 15
Inhaltsmangel	Seite 16
Willensmangel	Seite 16
Inominatverträge	Seite 19
SLA	Seite 22
Bonus-Malus-Systeme	Seite 23
Vertrauensschutz	Seite 24
Rechtsmissbrauchsverbot:	Seite 24
Verhandlungsmaxime	Seite 25
Untersuchungsmaxime	Seite 25
Beweislastumkehr	Seite 25
Beweisnot	Seite 25
Beweiserleichterung	Seite 25
Konkludentes Verhalten	Seite 27
Exkulpation	Seite 29

Begriff	Fundstelle
Verwirkungsfrist	Seite 33
Werklohn	Seite 37
Kostenansatz	Seite 37
Werkmangel	Seite 37
Prüf- und Rügeobliegenheit	Seite 37
Stillschweigende Genehmigung	Seite 37
Anzeigepflicht	Seite 37
Gewährleistung	Seite 38
Ersatzvornahme	Seite 39
Mäklervertrag	Seite 40
Agenturvertrag	Seite 40
Rechtshandlung	Seite 40
Tathandlung	Seite 40
Auffangvertrag	Seite 40
Interessenkollision	Seite 40
Kündigung zur Unzeit	Seite 40
Adäquater Kausalzusammenhang	Seite 41
Sorgfaltsbeweis	Seite 41
Befreiungsbeweis	Seite 41